



PERSONA

INTRODUCCIÓN

Como bien sabemos, el sujeto de la relación jurídica de derecho privado son las personas. Así, junto con el estudio de la Teoría General del Acto Jurídico y de la Teoría de la Ley, el derecho de las personas es uno de los núcleos esenciales para la comprensión sistemática del derecho privado en su conjunto.

El derecho de las personas tiene por objeto el estudio de toda la normativa legal relativa a la existencia y atributos de las personas. En ese sentido, las normas que fundamentan las distintas instituciones que encontraremos en este apunte se encuentran en el libro I “De las personas” y en el Título preliminar.

La persona, sujeto de la relación jurídica, es cualquier sujeto con la capacidad de tener derechos y obligaciones. Luego, como explica el artículo 54 del Código Civil, las personas se clasifican en personas jurídicas y naturales. En este apunte, nos dedicamos al análisis de las personas naturales, y de las personas jurídicas reguladas por el Código Civil. (Recordemos que muchas personas jurídicas se regulan por el derecho comercial).

Respecto a la persona natural, resultan especialmente relevantes las reglas relativas al nacimiento, la muerte, los atributos de la personalidad y, en particular, las reglas de la capacidad. En relación a la persona jurídica, revisten particular importancia las reglas relativas a su clasificación, sus atributos de la personalidad, y el régimen de responsabilidad por daños de y a las personas jurídicas.

ÍNDICE

1. Los sujetos del derecho.....	4
1.1 Persona y relación jurídica	4
1.2 Las personas naturales.....	4
1.2.1 Existencia natural	5
1.2.2 Existencia legal	8
1.3 La muerte de las personas naturales	10
1.3.1 Efectos jurídicos de la muerte.....	12
1.4 La muerte presunta	13
1.4.1 Períodos de la muerte presunta	14
1.4.2 Ley N° 20.577.....	17
2. Atributos de la personalidad.....	20
2.1 El nombre	21
2.2 La capacidad	26
2.2.1 Incapaces absolutos.....	27
2.2.2 Incapaces relativos	30
2.2.3 Otros aspectos relevantes en materia de capacidad	33
2.3 La nacionalidad	36
2.4 El domicilio.....	37
2.5 El Estado Civil.....	42
2.6 El patrimonio	52
3. Derechos de la personalidad	57
3.1 Cuestiones generales	57
3.2 Clasificación de los derechos de la personalidad	59
4. Las personas jurídicas.....	61
4.1 Cuestiones generales	61
4.2 Naturaleza jurídica	62
4.3 Clasificación de la persona jurídica.....	63
4.3.1 La persona jurídica de derecho público.....	64
4.3.2 La persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro	65
4.4 Atributos de las personas jurídicas	72
4.5 Responsabilidad de las personas jurídicas	74
4.6 Daño moral a las personas jurídicas	81

PERSONA

CAPÍTULO 1. LOS SUJETOS DEL DERECHO

1.1 PERSONA Y RELACIÓN JURÍDICA

1. Introducción

En derecho existe una distinción fundamental entre las personas, sujetos del derecho, y las cosas, objetos del derecho.

El término persona se refiere a la posibilidad de ser sujeto de una relación jurídica, y cuando la persona es sujeto de una relación jurídica se dice que es titular de un derecho.

Así, en términos generales, persona es todo ser o entidad con la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones.

2. Clasificación de las personas.

El art. 54 señala que las personas son naturales o jurídicas, por ende, de acuerdo al CC, son dos los tipos de personas, naturales y jurídicas.

Las naturales las define el artículo 55 del CC, como todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Estos se dividen en chilenos y extranjeros.

Las personas jurídicas se definen en el 545 del CC, como aquella persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

1.2 LAS PERSONAS NATURALES.

1. Concepto

Son personas los seres humanos. Definición del CC acentúa la igualdad de los individuos.

Art. 55 CC. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros.

Toda persona natural está dotada de un elemento que la teoría jurídica denomina personalidad. Consiste ésta en la aptitud para ser titular o adquirir derechos, o para ser titular de relaciones jurídicas.

La ley reconoce que tanto la persona jurídica como la natural están dotadas de personalidad por el sólo hecho de existir, de manera que la personalidad es inseparable de la persona y por ende irrenunciable.

En ocasiones la ley contiene una reglamentación especial para ciertas personas, en atención a su edad, estirpe u otra razón, pero esta reglamentación no constituye una vulneración de la personalidad de las mismas, o que tengan una capacidad disminuida o de otra naturaleza. Lo que sucede es que el legislador pretende precisamente proteger a estas personas que se encuentran en una situación diferente.

2. Existencia de las personas naturales.

Existe en esta materia un doble tratamiento legal:

- **Existencia natural**, comienza con la concepción o fecundación (cuando se unen las células sexuales masculina y femenina) y termina con el nacimiento, que marca el inicio de la existencia legal.
- **Existencia legal**, comienza con el nacimiento y termina con la muerte, la que podrá ser legal o presunta.

1.2.1 EXISTENCIA NATURAL

La existencia natural no significa que la criatura concebida y no nacida sea sujeto de derecho, ya que todavía no es persona, y sólo lo será cuando nazca. Sin embargo la ley le protege en diversos sentidos:

a.- Protección de la vida. Art.75 inc.1º CC.

Art. 75 CC. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento.

Este artículo permite la intervención del juez incluso de oficio, de lo que se desprende que aquí no sólo hay un interés particular comprometido. Esos son los hechos que dan origen a las llamadas acciones populares.

Esta norma se encuentra en concordancia con los arts. 342 a 345 del CP, resguardando la vida de la criatura que está por nacer sancionando el delito de aborto maliciosamente o culpablemente causado. Ahora bien, esto es fuera de los casos permitidos por la ley, modificación introducida por la Ley N°

21.030, de 23 de septiembre de 2017, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Las causales por las cuales se autoriza la interrupción del embarazo por un médico cirujano mediando la voluntad de la mujer embarazada, están señaladas en el Art. 119 y siguientes del Código Sanitario:

- i. La mujer que se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.
- ii. El embrión o feto que padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.
- iii. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación.

También se resguarda la vida del que está por nacer con los descansos que establezca la ley laboral para la mujer embarazada, como ocurre con la regulación del pre natal, según señala el art. 195 CT.

En el mismo sentido encontramos el art. 19 N°1 inc. 2 de la Constitución Política de la República al señalar expresamente que "La ley protege la vida del que está por nacer".

De igual manera, el artículo primero inciso final de la ley 14.908, sobre Abandono de familia y Pago de pensiones alimenticias, señala que "La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer".

b.- Protección de los derechos. art.77 CC

Art. 77 CC. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del Art. 74, inciso 2., pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido.

Hay en esta norma un verdadero efecto retroactivo, pues desde que hay un principio de existencia se entiende que la criatura existe, había nacido y vivía al momento de deferírsele los derechos. A través de esta ficción se pretenden evitar los actos que terceros pudieran haber ejercido sobre los derechos del no nacido, de manera que los actos ejecutados por estos terceros serán inoponibles.

La ley, para completar la protección de los derechos eventuales del que está por nacer, prevé la designación de un curador para éste. El art.343 se refiere a esto, señalando que se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que esta por nacer.

Algunos autores (Alessandri y Claro Solar) sostienen que los derechos eventuales son verdaderos derechos condicionales, donde la condición consiste en que la criatura nazca y constituya un principio de existencia, es decir, que viva.

Serían derechos condicionales suspensivos, de manera que cumplida la condición ella opera con efecto retroactivo, y por tanto se retrotrae al momento en que se defirieron los derechos.

Sin embargo, tal opinión no es compartida por cierto sector de la doctrina, argumentando que la condición constituye un elemento accidental del acto jurídico, y el nacimiento es más que eso. En base a ello parece más conveniente la explicación de la ficción que nos entrega el legislador.

Según esta última postura, en realidad quien tiene un derecho eventual es aquel que adquiriría el derecho si la persona no nace.

En relación a lo dicho, conviene tener a la vista los siguientes artículos:

Art. 243 CC. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer.

Art. 485 CC. Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, y en el tiempo debido, estarán a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el testamento del padre, o de un curador nombrado por el juez, a petición de la madre, o a petición de cualquiera de las personas que han de suceder en dichos bienes, si no sucede en ellos el póstumo. Podrán nombrarse dos o más curadores, si así conviniere.

Art. 962 inc.3 CC. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los diez años subsiguientes a la apertura de la sucesión.

1.2.2 EXISTENCIA LEGAL

Art. 74 CC. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.

1. El Nacimiento.

a) Requisitos del nacimiento:

1. Separación del hijo y de la madre.
2. Separación completa de la madre.
3. Que sobreviva un momento siquiera a la separación.

Desarrollo de los requisitos:

1. Separación del hijo y de la madre.
2. Separación completa de la madre. Existen a este respecto dos opiniones:
 - i. Para algunos basta que el cuerpo de la criatura haya salido al exterior, aun cuando se conserve unido a la placenta por el cordón umbilical. Lo importante es que tenga vida fisiológicamente independiente. La integridad del cordón umbilical no significa unión de los dos cuerpos, pues dicho cordón es sólo un anexo que no pertenece al cuerpo de la madre ni del niño.
 - ii. Para otros se requiere de la expulsión de la criatura del vientre materno y además el corte del cordón umbilical, puesto que sólo con estas dos circunstancias habría separación completa.

Se critica la última posición arguyendo que con esa postura se deja al nacimiento como un acto dependiente de la voluntad de un tercero, el que corta el cordón, siendo contraria a la naturaleza del nacimiento como un acto esencialmente natural. Pese a esto ambas posturas tienen adeptos en la doctrina.

3. Que sobreviva un momento siquiera a la separación.

El mismo Art.74 inc. 2 señala una serie de situaciones en que no se cumple con este requisito, y en las que por ende no hay nacimiento:

- A.- Cuando la criatura muere en el vientre materno.
- B.- Cuando perece antes de estar separada completamente de la madre.
- C.- Cuando no ha sobrevivido a la separación ni un momento siquiera.

Para determinar el momento en que se produce el nacimiento, es decir, cuando la criatura ha sobrevivido a la separación un momento siquiera, se han planteado dos teorías:

1. Teoría de la vitalidad. Requiere que haya en la criatura una manifestación de vida de cualquier tipo, sean sonidos, movimientos, etc.
2. Teoría de la viabilidad. Requiere que la criatura haya tenido la aptitud de seguir viviendo después de nacida, es decir, que ella sea viable.

La doctrina en general asevera que nuestra legislación exige una manifestación de vida, lo que se podrá probar por los medios legales, o sea, la teoría de la vitalidad.

Si la criatura sobrevivió a la separación un momento siquiera fue persona, y por tanto pudo adquirir y transmitir derechos.

Si la criatura no sobrevivió, no se produce tal efecto y, más aun, se reputa no haber existido jamás. Esta criatura concebida pero que no sobrevivió no se inscribe en el Registro de Nacimientos ni en el de Defunciones, sino que en un registro especial, más bien estadístico, que lleva el Registro Civil.

Para probar que una criatura sobrevivió un momento siquiera se puede recurrir a los medios que estableció la ley, porque lo que se prueba es un hecho. Existe a este respecto el examen de docimasia pulmonar hidrostática.

La concepción o fecundación.

Para que el derecho se adquiriera por la criatura que nace viva, es menester que haya estado concebida en el momento de la delación del derecho, Art. 77 CC.

Esta expresión se toma del derecho canónico (concepción). Es difícil poder probar con exactitud el momento en que se produce el proceso biológico de la fecundación. En todo caso a la ley le interesa fijar la época en que esto ocurre.

Para determinar la época de la concepción el Código Civil recurre a una presunción de derecho, en el art. 76 CC.

Art. 76 CC. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente: Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.

El hecho conocido aquí es el nacimiento, del cual se colige la época de la concepción que es el hecho desconocido. Es éste un plazo de días cabales, no

de meses, pues estos pueden variar en su número de días, y se cuentan de doce a doce de la noche.

Ej. Si el nacimiento se produjo el día 3 de abril a las 23 horas, debemos contar desde la medianoche del día 3 de abril.

Por regla general los nacimientos se producen entre los 270 y 285 días posteriores a la concepción, pero puede suceder que ocurra antes o bien después. Se ha criticado el hecho de que el art. 76 CC establezca una presunción de derecho, pues la experiencia médica demuestra que hay casos de gestación de más de 300 días y menos de 180 días.

Por este motivo la ley estableció la época de la concepción, fijando un tiempo mínimo de gestación de 180 días cabales y de la gestación máxima 300 días cabales, contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.

Como es una presunción de derecho no admite prueba en contrario. En todo caso, en caso de impugnación de paternidad, se puede probar que no se tuvo acceso a la mujer durante el plazo en que la ley presume que se produjo la concepción (120 días).

Importancia del art.76 CC:

1. Para la determinación de los derechos eventuales de la criatura que está por nacer (Art. 77 CC).
2. Para determinar la filiación matrimonial del hijo, puesto que será hijo matrimonial aquel concebido durante el matrimonio verdadero de sus padres, incluso matrimonio putativo (arts. 179, 180 CC).

1.3 LA MUERTE DE LAS PERSONAS NATURALES

Art. 78. La persona termina en la muerte natural.

1. Extinción de las personas naturales.

Si bien el Código Civil no define expresamente qué se entiende por muerte, podríamos decir que esta se ha conceptualizado tradicionalmente como la cesación de las funciones vitales del individuo. Su acaecimiento pone término a la persona, como señala el art.78.

Ahora bien, es necesario distinguir, como se ha hecho tradicionalmente, las distintas formas o vías para determinar cuándo se produce la muerte y, por tanto, se le pone fin a la persona natural:

- a. Muerte natural: Cesación de todos los fenómenos vitales del individuo, es un hecho natural que produce importantes consecuencias jurídicas. Tiene un desarrollo doctrinario.
- b. Muerte clínica: Estado en que se conservan algunas funciones vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma artificial, pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual. Esta conceptualización doctrinaria coincidiría con aquella incorporada en el Código Sanitario y en la ley sobre trasplante y extracción de órganos señaladas en las letras e) y f) siguientes.
- c. Muerte presunta: Regulación en Código Civil. Se pasará a desarrollar más adelante.
- d. Muerte a través de la comprobación judicial: Arts. 95-97 CC, se pasará a desarrollar más adelante.
- e. Muerte según la ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos: en su artículo 11 señala que para efectos de la extracción de órganos, la muerte se produce cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas. Esta circunstancia se acredita cuando: (1) no existe movimiento voluntario alguno durante una hora, (2) se presenta apnea luego de 3 minutos de desconexión del ventilador y (3) existe ausencia de reflejos del tronco encefálico.

La muerte de una persona natural se acredita por medio del certificado de defunción. Es la Ley del Registro Civil la que reglamenta cómo se lleva a cabo esta inscripción, en sus arts. 26, 44, 45 y 50, en la que debe consignarse incluso la hora en que se ha producido la muerte. Esto, debido a la importancia jurídica de este hecho.

Art. 26 LRC. Pasados tres días después de la defunción, no se podrá proceder a la inscripción sin decreto judicial. El juez calificará los motivos que hayan impedido la inscripción y si esta omisión se hubiere hecho con dolo o malicia, aplicará las sanciones establecidas en el Código Penal.

Art. 44 LRC. La inscripción de defunción se hará en virtud del parte verbal o escrito que, acerca de ella, deben dar los parientes del difunto o los habitantes de la casa en que ocurrió el fallecimiento o, en su defecto, los vecinos. Si el fallecimiento hubiere ocurrido en convento, hospital, lazareto, hospicio, cárcel, nave, cuartel u otro establecimiento público, el jefe del mismo estará obligado a solicitar la licencia o pase del entierro y llenar los requisitos necesarios para la respectiva inscripción en el Registro. Igual obligación corresponde a la autoridad de policía en el caso de hallarse un cadáver que no sea reclamado por nadie o del fallecimiento de una persona desconocida.

Art. 45 LRC. Al requerirse la inscripción de un fallecimiento, deberá presentarse un certificado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones o por el que haya asistido al difunto en su última enfermedad. Si se trata del fallecimiento de un párvulo, el Oficial del Registro Civil indagará si

el nacimiento ha sido inscrito previamente y si no lo estuviere, procederá a efectuar, también, esta inscripción. En dicho certificado se indicará, siendo posible, el nombre, apellido, estado, profesión, domicilio, nacionalidad y edad efectiva o aproximada del difunto; el nombre y apellido de su cónyuge y de sus padres; la hora y el día del fallecimiento, si constare o, en otro caso, las que se consideren probables, y la enfermedad o la causa que haya producido la muerte. La verificación de las circunstancias indicadas en el inciso precedente, siempre que no hubiere facultativo en la localidad, podrá ser substituída por la declaración de dos o más testigos, rendida ante el Oficial del Registro Civil o ante cualquiera autoridad judicial del lugar en que haya ocurrido la defunción. Esta declaración deberá ser hecha, de preferencia, por las personas que hubieren tratado más de cerca al difunto o que hubieren estado presentes en sus últimos momentos, de todo lo cual se dejará testimonio expreso en la inscripción.

Art. 50 LRC. Son requisitos esenciales de la inscripción de una defunción, la fecha del fallecimiento y el nombre, apellido y sexo del difunto.

Es importante señalar que algunos autores como Carlos Ducci o Máximo Pacheco diferencian sólo dos grandes vías para determinar cuándo se produce la muerte:

- i. Muerte Real:
 - a. Cadáver identificable: Código Sanitario y Ley de Trasplante y extracción de Órganos.
- ii. Muerte presunta: regulación propia de la muerte presunta y comprobación judicial de muerte según los actuales artículos 95-97 CC).

1.3.1 EFECTOS JURÍDICOS DE LA MUERTE

1. La sucesión se abre al momento de la muerte (Art. 955 y 962 CC).
2. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges (Art. 42 LMC).
3. El acuerdo de unión civil se disuelve por la muerte de uno de los convivientes civiles (Art. 26 Ley 20.830)
4. La muerte determina la extinción de los derechos intransmisibles. Por ejemplo, el derecho de uso y habitación.
5. Ciertos contratos se extinguen por la muerte de uno de los contratantes. Por ejemplo: sociedad, mandato, comodato.
6. La oferta se extingue por la muerte del proponente, pierde vigencia.
7. La muerte determina la emancipación de los hijos, salvo que quede el padre o la madre con vida (Art. 270 N°1 CC).

8. Algunas instituciones terminan por la muerte del que las desempeña. Por ejemplo, el albaceazgo termina por muerte del albacea (Art. 1279 CC).
9. Por la muerte se extinguen determinadas acciones civiles. Por ejemplo, la acción para solicitar el divorcio.

Los comurientes.

El art. 79 CC señala que si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubieran perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras.

Esta es una presunción simplemente legal, aceptándose cualquier medio de prueba. Su importancia radica principalmente en la sucesión por causa de muerte a propósito de lo descrito en el art. 958 CC.

1.4 LA MUERTE PRESUNTA

1. Presunción de muerte por desaparecimiento.

La muerte presunta es la declarada por el juez, en conformidad a las reglas legales, respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no. El juez, partiendo de ciertos antecedentes, presume la muerte de una persona.

El art. 80 CC señala que se presume muerto al individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que se expresan más adelante.

Hay ciertos hechos, ciertas circunstancias que van imponiendo en forma gradual la idea de que la persona que ha desaparecido ha muerto. Estos hechos son:

- 1.- Que la persona ha desaparecido.
- 2.- Falta de noticias acerca de ella.
- 3.- Transcurso de cierto tiempo.

Hay también otros hechos que revisten un mayor grado de convicción en cuanto a que la persona haya muerto, por ejemplo, un accidente.

La presunción contenida en el art. 80 es simplemente legal.

2. Intereses en juego en la declaración de muerte presunta.

Se sostiene, en doctrina, que los intereses que se tiende a resguardar son:

- Del ausente o desaparecido.
- De los terceros que tengan derecho a la sucesión de tal desaparecido o ausente.
- De la sociedad en general, al desconocer la suerte que van a seguir los bienes del desaparecido.

Estos intereses, su resguardo, son el objeto de la muerte presunta.

3. Requisitos para que tenga lugar la declaración de muerte presunta

- a) Que sea declarada por sentencia judicial.
- b) Que la declaración se haga en conformidad a las disposiciones del procedimiento.
- c) Que el individuo haya desaparecido, esto es, se haya ausentado de su domicilio.
- d) Que no se tengan noticias de su existencia.

1.4.1 PERÍODOS DE LA MUERTE PRESUNTA

En la muerte presunta se distinguen 3 períodos: período de mera ausencia, periodo de posesión provisoria y periodo de posesión definitiva.

1. Período de mera ausencia:

Desde que han dejado de tenerse noticias del ausente. Es un estado de hecho en el cual el objetivo fundamental es proteger los derechos del ausente, para lo cual se tiende a la administración de sus bienes.

Dura normalmente 5 años. Sin embargo, dura menos en los siguientes casos:

- En la pérdida de una nave o aeronave se redujo el término de 6 meses por 3 meses con la dictación de la Ley 20.577 de 8 de febrero de 2012, dictada tras el accidente de Juan Fernández (Art. 81 N° 8 CC).
- Si la desaparición se produjo en un sismo o catástrofe se redujo el término de 1 año a 6 meses con la dictación de la Ley 20.577 pero esta vez el propósito fue otorgar soluciones a las víctimas del terremoto y tsunami del 27 de febrero (Art. 81 N° 9 CC)

Hay que advertir que no se modificó el plazo de un año desde el día presuntivo de muerte para la disolución del matrimonio que prevé el art. 43 inc. 3º de la ley N° 19.947, Ley de Matrimonio Civil, por lo que este seguirá vigente.

Los dos períodos siguientes son consecuencia de la declaración de muerte presunta.

Requisitos de la declaración de muerte presunta (Art. 81 CC):

- i. Prueba de la ausencia, lo que implica que no se hayan tenido noticias y se hayan hecho las gestiones necesarias para averiguar el paradero.
- ii. Citación del desaparecido: 3 publicaciones en el DO. Cada una de ellas debe realizarse con más de 2 meses de diferencia.
- iii. Oír al defensor de ausentes.
- iv. Transcurso de los plazos señalados por la ley. La solicitud se puede hacer luego de 3 meses de la última citación.
- v. Publicación de la sentencia en el DO.

Día presuntivo del a muerte: El juez la fijará (Art. 81 CC):

- a) Norma general: último día del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias.
- b) En caso de herida grave en la guerra u otro peligro semejante: día de la acción de guerra o peligro; si no es determinado, término medio entre principio y fin de la época en que pudo ocurrir. Lo mismo en caso de pérdida de nave o aeronave.
- c) En caso de sismo, catástrofe o fenómeno natural: fecha de tal evento.

Si el ausente ha dejado representante o poder (por ejemplo, en el testamento), dicha administración se considerará suficiente y nos e tomarán medidas adicionales. De lo contrario, se procede a nombrar curador de bienes del ausente (Arts. 473 y siguientes).

2. Período de posesión provisoria:

Es eventual, pues no existe en los casos los casos de guerra o peligro semejante ni sismo, catástrofe, pérdida de nave o areonave, o fenómeno natural recién señalados, en los cuales se concede de inmediato la posesión definitiva. Ocurre lo mismo en el caso de que, pasados 5 años desde las últimas noticias, se pruebe que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido.

Efectos del decreto de posesión provisoria:

- a) Término de la sociedad conyugal o participación en los gananciales (Art. 84 y 1764 N° 2 CC).
- b) Emancipación de los hijos (Art. 270 N° 2 CC). Salvo que corresponda a otra persona ejercer patria postestad.

- c) Apertura de la sucesión (Art. 84 CC): si hay testamento, se abre o publica. Si no hay testamento se da la posesión provisoria a los herederos presuntivos, si no los hay, se declara la herencia yacente.
- d) Los poseedores provisorios deben prestar caución de conservación y restitución; mientras administran y usufructúan haciendo suyos los respectivos frutos e intereses (Art. 89 CC).
- e) Los poseedores provisorios deben formar un inventario solemne de los bienes, o revisar y rectificar con la misma solemnidad el inventario que ya exista (Art. 86 CC).
- f) Los poseedores provisorios representan a la sucesión en las acciones y defensas contra terceros (Art. 87 CC).
- g) Los poseedores provisorios pueden vender los bienes muebles con autorización del juez, oído el Defensor de Ausentes. Los bienes raíces no pueden enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesario o utilidad evidente declarada por el juez previa eudiencia del Defensor de Ausentes. La venta de los bienes debe hacerse en pública subasta (Art. 88).

Este período termina porque el desaparecido reaparece (termina muerte presunta), se sabe con certeza la fecha verdadera de la muerte del desaparecido (termina muerte presunta) o porque se concede la posesión definitiva.

3. Período de posesión definitiva:

El juez concederá posesión definitiva transcurridos 10 años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera fuere la edad del desaparecido.

Efectos del decreto de posesión definitiva:

- a) Disolución del matrimonio. En los casos en que no hay posesión provisoria, los plazos son distintos: 1 año desde el día presuntivo de la muerte en caso de sismo, catástrofe y pérdida de nave o aeronave; 5 años desde las últimas noticias en caso de herida de guerra u otro peligro o habiendo transcurrido 70 años desde el nacimiento (Art. 43 LMC)
- b) Todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido podrán hacerlos valer (Art. 91 CC). Por ejemplo, el legatario podrá reclamar la cosa legada, el nudo propietario.

- c) Apertura de la sucesión en caso de no haber posesión provisoria (Art. 90 inc. 3º CC).
- d) Cancelación de las cauciones constituidas por los herederos provisorios y cesación de las restricciones impuestas a ellos (Art. 90 inc. 1º y 2º CC).
- e) Puede procederse a la partición de los bienes.

Este decreto puede rescindirse si el desaparecido reaparece (en cualquier momento, contra él no corre prescripción), a favor del desaparecido, de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su cónyuge por matrimonio contraído en esa época (Art. 93 CC).

Pronunciada la rescisión, los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado en que se encuentren, y son considerados poseedores de buena fe. Respecto a los terceros, el reaparecido no tiene acciones (Art. 94 reglas 4ª y 5ª CC). Ocultar la verdadera muerte o existencia del desaparecido constituye mala fe (Art. 94 regla 6ª CC).

Inscripciones a las que da lugar la muerte presunta:

- Sentencias ejecutoriadas que declaran la muerte presunta: se deben inscribir en el libro de defunciones del SRCEI correspondiente al tribunal que hizo la declaración (Art. 5 N°5 Ley N° 4.808). Sanción: no se podrá hacer valer en juicio.
- Decreto de posesión definitiva: debe inscribirse en el CBR correspondiente a la comuna del último domicilio del desaparecido en Chile (comuna en que se decretó la muerte presunta). Sanción: inoponibilidad a terceros.

1.4.2 LEY N° 20.577

La ley 20.577, publicada el 8 de febrero de 2012, además de reducir el plazo de espera para que el juez declare la muerte presunta y conceda la posesión efectiva de los bienes del o de los desaparecidos, introdujo en nuestro sistema civil una nueva modalidad de comprobación de la defunción: el supuesto de muerte cierta pero con desaparición del cadáver.

En este último aspecto la ley es más innovadora puesto que introduce, como existe en otros ordenamientos (España, Argentina, Perú, Quebec), un supuesto de muerte que es cierta, no meramente probable y presumible por el hecho del desaparecimiento de alguien que no retorna, pero cuya comprobación no puede hacerse mediante la prueba ordinaria que consiste en certificar la defunción por el examen del cadáver o los restos mortales del difunto. Esta nueva forma de comprobación de la muerte se inserta en el párrafo 4 del título II del libro I, en los nuevos artículos 95 a 97, que originalmente regulaban la muerte civil, derogada por la ley N° 7.612, de 1943, y queda así patente que

no es un tipo de muerte presunta, sino de otra forma de acreditar la muerte que ciertamente ha acaecido.

Según el nuevo art. 95, "toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación". Se agrega que "Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver". Como se ve, en estos casos, no será necesario esperar ningún plazo para pedir la comprobación de la muerte, porque no se trata de que haya desaparecido una persona y de ello pueda deducirse la muerte por un juicio de probabilidad basado en su no retorno durante un determinado plazo. Lo que ha desaparecido o no es posible identificar es el cadáver, pero la muerte ha tenido lugar más allá de toda duda razonable.

Un caso claro es el de los tripulantes del trasbordador espacial Challenger que se desintegró en su lanzamiento el 28 de enero de 1986, y entre nosotros el de los pasajeros del Casa 212 que se estrelló en Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011.

La comprobación se realizará a petición de un legítimo interesado y en un procedimiento no contencioso. El juez deberá ser especialmente cuidadoso para dictar la sentencia cuando efectivamente se haya demostrado la certeza moral del fallecimiento y la identidad de la persona fallecida, para evitar que la nueva institución sea utilizada abusivamente. La ley exige que un extracto de la resolución judicial se publique en el Diario Oficial como una medida de publicidad y seguridad jurídica, aunque se olvida de condicionar la inscripción en el Registro Civil de la sentencia al cumplimiento de esta medida.

Sobre la revocación de la resolución, ya sea por comprobarse que la persona está viva o ha muerto en otra fecha, la nueva regulación se remite "al párrafo precedente" (art. 97), con lo cual alude a la rescisión del decreto de posesión definitiva de la muerte presunta regulado en los arts. 93 y 94 del Código Civil.

La reforma omite aclarar un aspecto importante: su efecto en el tiempo. Ningún artículo dispone si se podrá aplicar esta normativa a personas que hayan desaparecido con anterioridad al 8 de febrero de 2012, fecha de su entrada en vigencia. No obstante, existe una clara intención del legislador de que ella opere con efecto retroactivo. En primer lugar, por cuanto la iniciativa tuvo como finalidad favorecer el trámite de inscribir las defunciones de los desaparecidos en el accidente de Juan Fernández y sería absurdo que no pudiera aplicarse a ellos. En segundo lugar, porque tratando de respetar la sensibilidad de los familiares de las detenidos desaparecidos, se declaró expresamente que no se aplicará la comprobación judicial de la muerte cierta

en los casos regulados por la ley Nº 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (art. 3 de la ley Nº 20.577). Si tuvo que declararse expresamente la improcedencia de la aplicación a personas que claramente desaparecieron antes de la entrada en vigor, es porque se entendía que, de no haberse establecido la excepción, la reforma les era aplicable.

CAPÍTULO 2. ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.

Los atributos de la personalidad son las propiedades o características inherentes a toda persona.

La personalidad es la aptitud para tener la calidad de titular de derechos y obligaciones.

Luego, la personalidad dice relación con la posibilidad de la persona de tener vínculos jurídicos con otros individuos, en los cuales resulta de gran importancia que los sujetos intervinientes estén perfectamente individualizados.

Para ello, la ley atribuye a toda persona, sea natural o jurídica, ciertos atributos o condiciones.

Los atributos de la personalidad son propiedades o características inherentes a toda persona, que importan una serie de ventajas y prerrogativas, como también un cúmulo de deberes, molestias y obligaciones.

Estos atributos se refieren tanto a las personas naturales como jurídicas, salvo ciertas variantes.

Estos atributos son:

1. Nombre
2. Capacidad de goce
3. Nacionalidad
4. Domicilio
5. Estado Civil
6. Patrimonio
7. Derechos de la personalidad

2.1. EL NOMBRE

1. Concepto.

Nombre: designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y jurídica, distinguiéndola de las demás.

Está constituido por 2 elementos:

- 1.** Pronombre o nombre propiamente tal (*nombre propio o de pila*): individualiza a la persona dentro del grupo familiar.
- 2.** Apellido(s) o nombre patronímico o de familia: señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado.

2. Formación del nombre.

En este punto hay que distinguir en cuanto a la filiación del individuo:

- a)** La ley establece que en la inscripción deben figurar los nombres de padre y madre. Art. 31 LRC. El reglamento del Registro Civil en su art. 226 señalan que llevarán primero el apellido del padre y luego el de la madre.
- b)** Tratándose del hijo adoptado, el art. 26 de la ley 19.620 señala que la nueva inscripción de nacimiento del adoptado contendrá las indicaciones que señala el artículo 31 de la ley 4.808.
- c)** En los casos de filiación desconocida, el reglamento no establece norma alguna, desprendiéndose que tendrá los nombres y apellidos que señale quien solicita la inscripción.

Con todo, es relevante tener en consideración las modificaciones introducidas por la ley 21.334 Sobre Determinación del Orden de los Apellidos por Acuerdo de los Padres, publicada el 14 de mayo de 2021. Así, introduce modificaciones al Código Civil y el actual artículo 58 ter de dicho cuerpo normativo señala: "El primer apellido del o los progenitores se transmitirá a sus hijos, conforme el orden que, según los casos, se determine en aplicación de las reglas siguientes:

1. En la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes, los progenitores determinarán, de común acuerdo, el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos, que valdrá para todos sus hijos comunes. En caso de no manifestarse acuerdo al momento de inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá su voluntad de que el orden de los apellidos sea determinado mediante sorteo ante el Oficial del Registro Civil.
2. En toda inscripción de nacimiento en que al tiempo de la inscripción quede determinada la filiación del nacido respecto de ambos progenitores, el oficial

del Registro Civil procederá según el orden de los apellidos fijado en la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes de dichas personas; y si no tuvieran más hijos comunes, según el orden que se determine al practicarse la inscripción, de conformidad a lo dispuesto en la regla precedente.

3. En la inscripción de nacimiento de un hijo cuya filiación al tiempo de la inscripción quede determinada sólo respecto de uno de los progenitores, se inscribirá al nacido con el respectivo primer apellido de dicho progenitor. En este caso, cuando con posterioridad obrare determinación de la filiación no determinada al tiempo de la inscripción de nacimiento, si hubiere otro u otros hijos comunes de dichos progenitores, se estará al orden de los apellidos fijado en la inscripción de nacimiento del primero de sus hijos comunes. Si, por el contrario, no hubiere más hijos comunes de dichos progenitores, el primer apellido del progenitor que quedó determinado al momento de la inscripción de nacimiento antecederá al otro apellido, a menos que, no habiendo el hijo alcanzado la mayoría de edad, los progenitores manifiesten, de común acuerdo, su voluntad de que se proceda con el orden inverso.

Con todo, para aplicar las reglas señaladas en el inciso anterior, previamente el oficial del Registro Civil deberá verificar si existieren en los registros hijos inscritos a nombre de cada uno de los progenitores.

Fijado en la inscripción de nacimiento el orden de los apellidos del primero de los hijos comunes, los demás hijos que dos progenitores tengan en común deberán inscribirse siempre con el mismo orden de apellidos, conforme a las disposiciones del presente artículo.

Las inscripciones de nacimiento y las manifestaciones del acuerdo de los progenitores, respecto del orden de los apellidos, se practicarán de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, y en la forma que determine el reglamento."

Así, muchas disposiciones se refieren al nombre, y el CP lo protege en algunos delitos.

3. Características del nombre.

Como bien extrapatrimonial, es indivisible, irrenunciable, imprescriptible, intransferible, intransmisible (salvo el derecho de los hijos de usar el patronímico de sus padres), inembargable e inmutable (salvo ciertas excepciones).

4. Cambio del nombre.

El nombre se puede cambiar por dos vías:

- Vía consecuencial o indirecta: por un cambio en una situación jurídica por sentencia judicial. Ej. Filiación.
- Vía directa: La Ley 17.344 autoriza el cambio de nombre y apellidos. Se puede solicitar una sola vez, por 3 órdenes de razones:
 - a)** Si menoscaban moral o materialmente a la persona.
 - b)** Si la persona ha sido conocida por un nombre distinto en la vida civil durante más de 5 años.
 - c)** Para que la inscripción no haga manifiesta una filiación no matrimonial o no determinada (*para agregar o cambiar apellidos*).
 - d)** Las personas que no tienen nombre de origen español pueden pedir cambio por traducción (no es propiamente cambio de nombre).

A propósito de la Ley 17.344 conviene tener presente lo siguiente:

- Se solicita ante el Juzgado de letras de la comuna del domicilio del peticionario.
 - La sentencia que lo autoriza debe inscribirse en el SRCEI para producir efectos legales.
 - Modificada la partida solo se podrá usar el nombre nuevo.
 - Se sanciona penalmente el mal uso del nuevo o antiguo nombre.
- e)** Con todo, la misma ley 21.334 previamente señalada, agrega los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quáter a la ley 4.808, sobre Registro Civil. Así, el artículo 17 bis señala "Toda persona mayor de edad podrá, por una sola vez, y en la forma que dispone el presente artículo, solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio de orden de apellidos determinados en su inscripción de nacimiento.

La solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá indicar el nuevo orden de los apellidos con los que quiere ser identificada la persona requirente, así como la petición expresa de rectificar los registros con que se le hubiera identificado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven en dicho Servicio (...).

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, no podrán solicitar el cambio de orden de los apellidos de que trata el presente artículo, las personas que se encontraren actualmente procesadas o formalizadas, o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontraren sujetas a otras medidas cautelares personales, o hubieren sido condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar el correspondiente requerimiento en conformidad a las normas contenidas en la ley N° 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos en los casos que indica y modifica ley N° 4.808, sobre Registro Civil (...), siempre que no se trate de personas condenadas por alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V y VI del Título Séptimo del Libro

Segundo del Código Penal (...)"'. La citada norma procede a detallar el procedimiento para la solicitud referida.

Señalan los incisos quinto y sexto del artículo 17 ter: "El cambio del orden de los apellidos sólo operará respecto del solicitante, sin que resulte extensivo a los ascendientes, y no alterará la filiación. Por su parte, el cambio del orden de los apellidos del solicitante provocará el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, éstos deberán manifestar su consentimiento, mediante declaración escrita extendida ante el Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos menores de edad. Cuando en tales términos corresponda proceder con el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la orden de servicio por la que acoja la solicitud de cambio del orden de los apellidos del solicitante, además deberá ordenar las correspondientes rectificaciones en las partidas de nacimiento de todos los hijos menores de edad, procediéndose con las modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones, de conformidad con las reglas del presente artículo.

Los hijos mayores de edad de quien obtenga el cambio del orden de sus apellidos por el procedimiento de esta ley o mediante el procedimiento de la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos, podrán solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio del respectivo apellido de transmisión, caso en el cual se procederá con la rectificación en la partida de nacimiento; modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones, de conformidad con las reglas del presente artículo.

Así, a modo de conclusión, la ley 21.334 agrega dos nuevas causales a la ley 17.344 que permite el cambio de nombres y apellidos:

"d) Cuando el solicitante desee invertir el orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento.

e) Cuando el solicitante desee usar uno u otro apellido de un ascendiente en línea recta hasta el segundo grado."

Seudónimo: nombre imaginario que voluntariamente adopta una persona para esconder o caracterizar su verdadera personalidad en una actividad determinada. El CC no reglamenta ni se refiere al seudónimo. Pero sí se refiere a él la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, para la cual el seudónimo forma parte del derecho moral, y como tal, es un derecho extrapatrimonial.

5. Derecho al nombre.

1) Calidad jurídica:

- Algunos sostienen que es un derecho subjetivo, no habiendo acuerdo sobre si se trata de un derecho de la propiedad o de la personalidad.
- Otros sostienen que se trata de una institución de policía civil.
- Finalmente, hay quienes afirman que es ambas cosas.

2) Contenido:

- Usar el nombre.
- Vedar a los demás del uso indebido del nombre (usurpación del nombre, delito penal).

2.2. LA CAPACIDAD¹

Se distinguen en nuestro ordenamiento jurídico dos tipos de capacidad: una, que consiste en la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, denominada comúnmente capacidad de goce; y otra, que consiste en la aptitud de las personas humanas para obrar por sí mismas en la vida civil, denominada capacidad de obrar o, simplemente, de ejercicio.

1. Capacidad de goce.

La capacidad de goce es consustancial al concepto de persona, toda vez que lo que constituye en esencia la personalidad es la posibilidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. De modo que es inconcebible que pueda existir una persona que carezca de esta capacidad o que, teniéndola, carezca de personalidad.

En realidad uno y otro concepto se identifican. Y porque nadie puede carecer de capacidad de goce, se ha preferido definirla más que como una aptitud legal, que se puede tener o no, lo que implica negarla o concederla de manera absoluta sin matices o instancias intermedias, como un grado de aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, concepto que encierra una idea relativa, puesto que admite la posibilidad jurídica de encontrarse una persona inhabilitada para la adquisición de un derecho determinado, sin perjuicio de conservarla para la adquisición y goce de los demás.

No hay, entonces, incapacidades de goce absolutas. Sólo existen en nuestro ordenamiento jurídico incapacidades para adquirir un derecho en particular, fundadas en principios de orden público o en consideraciones de índole moral. Sin embargo, algunos han querido ver en las incapacidades para suceder (Arts. 962 y siguientes), una especie de incapacidad de goce².

2. Capacidad de ejercicio.

La capacidad de ejercicio, es la aptitud de las personas para obrar por sí mismas en la vida civil. Pero esta aptitud está constituida por un requisito

¹ Texto base: La persona natural. Autor: ALBERTO LYON PUELMA. 2006. Pág. 172- 191

² Existen ciertos casos de excepción en que nos enfrentamos a lo que algunos llaman "incapacidades de goce", como por ejemplo las incapacidades para suceder. Ahora bien, ¿son verdaderamente incapaces de goce?

- Algunos: sí, en cuanto no se está afectando con estas disposiciones de manera general el atributo de la personalidad (nunca se pierde de manera general).

- Otros (mayoría): más que hablar de "incapacidades de goce", hay que hablar de prohibiciones legales para la adquisición de determinados derechos (entre ellos Claro Solar).

concreto que debe concurrir en las personas, lo que la diferencia de la aptitud para ser titular de derechos, que sólo requiere la atribución de personalidad por el ordenamiento jurídico. Este requisito que supone o más bien constituye la capacidad de ejercicio es la existencia de una voluntad capaz de discernir con responsabilidad y con la debida independencia o libertad cuales son los actos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales que desea realizar.

Art. 1445 inc. final CC. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma, y sin el ministerio ni autorización de otra persona.

El principio general establecido en nuestro Código Civil es que todas las personas humanas son capaces, salvo aquellas que la ley ha declarado expresamente incapaces. Así lo dispone el artículo 1.446 del Código Civil.

En consecuencia, la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. Y el principio legal precedentemente expuesto "significa, también, que cada incapaz, de derecho o de hecho, lo es únicamente en la medida establecida por la ley". Es por esta circunstancia que la incapacidad no puede extenderse por analogía a otros supuestos no previstos en la norma.

3. Enumeración de los incapaces.

Art. 1446 CC. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces.

Art. 1447 CC. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes.

Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.

2.2.1 INCAPACES ABSOLUTOS

1. Dementes

Nuestro Código Civil no define la demencia, pero con esa expresión se refiere a la situación en que se encuentra una persona que, por alteración de sus facultades mentales, carece de la aptitud necesaria para dirigir su persona o para administrar sus bienes.

De esta manera, la decisión para considerar demente a una persona deberá ser precedida de una investigación científica y práctica que tendrá siempre por objeto establecer las siguientes circunstancias: a) Que la persona adolece de una enfermedad mental; y b) Que esa enfermedad mental produce en el individuo una ineptitud para administrar competentemente lo suyo.

Según lo dispone el artículo 456 del Código Civil, "el adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos". De esta manera, el demente que es privado por sentencia judicial del derecho a administrar sus bienes, se dice que se encuentra interdicto por causa de demencia.

La sentencia que declara la interdicción de una persona por causa de demencia produce dos efectos fundamentales:

- a) Priva al demente de la administración de sus bienes y le nombra un curador general que vele por sus intereses; y
- b) Trae como consecuencia que todos los actos del demente, posteriores al decreto de interdicción, son nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido (artículo 465 inc. 1 CC).
- c) Invierte la carga de la prueba. Antes del decreto, se tendrá que probar cada vez que se quiera anular un acto celebrado por el demente que este justamente carece absolutamente de discernimiento. Por el contrario, una vez que existe decreto, no es necesario probar circunstancia alguna que acredite la demencia.

Art. 465 CC. Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente.

En consecuencia, el adulto que no se halla en estado habitual de demencia sino que le aqueja un pasajero estado de enajenación, no puede ser privado de la administración de sus bienes y, por consiguiente, no puede ser declarado en interdicción por demencia. Esto último, insistimos, no significa que la persona no haya sido incapaz absoluto durante el estado de demencia porque el demente es considerado incapaz absoluto, ya sea que obre en un estado habitual o se trate de un estado transitorio.

2. Impúberes

Según el artículo 26 del CC se llama impúber al varón que no ha cumplido catorce años y a la mujer que no ha cumplido doce años.

Pero dentro de los impúberes mismos se distingue entre aquellos que no han cumplido siete años, llamados infantes o niños y aquellos que si lo han hecho.

Es de interés distinguir esta categoría de impúberes porque a los mayores de 7 años, el artículo 723 CC les reconoce cierta capacidad en materia posesoria al disponer que sólo los infantes son incapaces para adquirir por su voluntad la posesión, sea por sí mismos o por otra persona. Por otra parte, en materia de responsabilidad extracontractual civil, el artículo 2319 CC establece que no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años.

3. Sordomudos que no se pueden dar a entender claramente

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1447 CC, es incapaz el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. En consecuencia, el sordo o el sordomudo que puede hacerlo no está privado de la administración de sus bienes y es plenamente capaz.

Se fundamenta la incapacidad en que el sordo o sordomudo al no poder dar a entender su voluntad, al estar impedido de expresar su voluntad, no es posible conocerla.

Según nuestro Código Civil, el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, debe ser puesto en interdicción cuando ha llegado a la mayoría de edad (art. 470 en relación con el 457 del CC).

4. Cómo actúan en la vida jurídica los incapaces absolutos.

El absolutamente incapaz sólo puede actuar en la vida jurídica representado por la persona que tiene su representación legal. Son representantes legales, por ejemplo, el padre o madre bajo cuya potestad vive el incapaz y el tutor o curador del pupilo (Art. 43 CC.).

Los actos que ejecute un absolutamente incapaz por sí mismo serían, en estricto rigor, inexistentes, pues se supone que el incapaz absoluto carece de voluntad o no puede expresarla.

Sin embargo, nuestra legislación civil sanciona expresamente los actos de los absolutamente incapaces que actúan por sí mismos con la nulidad absoluta (Art. 1682 inciso 2 CC). Esto significa que el acto que celebra el incapaz sin estar debidamente representado existe, nace a la vida del derecho, pero con un vicio que hace posible su declaración de nulidad. Finalmente, cabe tener presente, que de conformidad con lo prescrito por el inciso 2 del artículo 1447 CC, los actos de los absolutamente incapaces no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución.

2.2.2 INCAPACES RELATIVOS

1. Menor adulto

Los menores adultos son aquellos que han dejado de ser impúberes y que no han cumplido todavía 18 años de edad. En otras palabras, son menores adultos las mujeres mayores de 12 años y los hombres mayores de 14, que no hayan cumplido 18 años de edad.

Los menores adultos son incapaces relativos porque sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respetos.

La incapacidad relativa del menor se extiende a actos judiciales y extrajudiciales.

En efecto, el menor de edad no puede comparecer en juicio como actor sino autorizado o representado por su padre, madre o ambos. Asimismo, en las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse al padre, madre o ambos para que autorice o represente al hijo en la litis (art. 264). Sin embargo, no es necesario la intervención paterna, materna o de ambos para proceder criminalmente contra el hijo (art. 266).

En lo que se refiere a materias extrajudiciales, los actos o contratos celebrados por el menor teóricamente son nulos relativamente por falta de capacidad, a menos que hayan sido autorizados por su padre, madre, ambos o por su curador, en su caso. Sin embargo, la situación del menor adulto que ejerce o ha ejercido una profesión, industria u oficio es bastante especial, pues no cabe hablar propiamente de una incapacidad de ejercicio.

En lo que se refiere a los actos de familia, no puede decirse que existe una regla definida. Con anterioridad, podían contraer matrimonio válidamente si eran mayores de 16 años, circunstancia que fue modificada por la ley 21.515 que establece en su artículo 2º que el matrimonio que se celebre con un menor de edad será nulo y, en su artículo 5º señala que no pueden contraer matrimonio los menores de dieciocho años. Sin embargo, el menor adulto sí puede otorgar testamento (art. 262). En lo tocante a la repudiación del reconocimiento de su filiación el artículo 191 y 192 CC, exigen la mayoría de edad, y mientras el menor de edad no llegue a la mayoría de edad nadie podrá repudiarla por él.

2. Interdicto por disipación

Disipador o pródigo es aquel que ha demostrado una falta total de prudencia en la administración de sus bienes, desperdiciando y consumiendo su hacienda o caudal en gastos inútiles y vanas profusiones.

La prodigalidad, es por consiguiente, un concepto relativo que requiere de la concurrencia de dos elementos o requisitos:

- a) Los gastos en que ha incurrido el supuesto disipador deben de ser

considerados excesivos atendido las particularidades de su patrimonio. En efecto, la prodigalidad debe necesariamente ser apreciada en relación a los

recursos de que el sujeto dispone; pues lo que para algunos resulta excesivo para otros será sólo un pequeño egreso injustificado; y

b) Debe tratarse de gastos que sólo tengan por causa el apego a una vida desordenada, irracional y caprichosa;

Para que proceda la interdicción por causa de disipación debe tratarse de actos y hechos repetidos y habituales. Así lo señala expresamente el artículo 445 CC que dice: "La disipación deberá probarse por hechos repetidos que manifiesten una falta total de prudencia".

Ahora bien, para que el disipador o pródigo pueda ser considerado incapaz, es condición esencial que se haya dictado el decreto de interdicción por tal motivo. De lo contrario, el disipador es plenamente capaz y los actos o contratos que ejecute o celebre serán plenamente válidos.

La sentencia que declara la interdicción de una persona por causa de prodigalidad, produce tres efectos fundamentales:

- a) Provoca la incapacidad relativa del disipador.
- b) Priva al pródigo de la administración de sus bienes y le nombra un curador.
- c) Trae como consecuencia que todos los actos o contratos del disipador posteriores al decreto de interdicción adolezcan de nulidad relativa.

3. Cómo actúan en la vida jurídica los incapaces relativos

Los relativamente incapaces pueden actuar válidamente en la vida jurídica representados o autorizados por su representante legal. De este modo, el contrato en que es parte un incapaz relativo puede haber sido celebrado directamente por el representante legal, a nombre del incapaz, o directamente por el incapaz relativo, autorizado por su representante legal.

Por excepción, la ley permite que los incapaces relativos ejecuten ciertos actos sin necesidad de representación o de autorización: tal ocurre, por ejemplo, en actos personalísimos como el reconocimiento de un hijo natural.

Los actos que ejecuten los relativamente incapaces sin la autorización o representación del representante legal se sancionan con la nulidad relativa, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 1682 inciso final CC. Sin embargo, y en atención a que la ley considera que los incapaces relativos tienen suficiente juicio o discernimiento, las obligaciones contraídas por éstos tienen la calidad de naturales y pueden ser caucionadas por terceros (Art. 1470 y 1472 CC). Sin embargo, el artículo 1470 N° 1 CC sólo menciona a los menores adultos, siendo objeto de discusión doctrinaria si abarca también a los interdictos por disipación, pues algunos consideran que están interdictos precisamente por carecer de suficiente juicio y discernimiento.

Pero se debe advertir que el menor adulto es capaz para administrar su peculio profesional, o industrial (artículo 251 CC, que señala que el hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de su peculio profesional o industrial). No obstante, debe recabar la autorización judicial para enajenar o gravar los inmuebles que formen parte del peculio profesional (Art. 254 CC).

La situación del menor adulto que ejerce o ha ejercido una profesión, industria u oficio es bastante especial, pues no cabe hablar propiamente de una incapacidad de ejercicio. Conforme a lo dispuesto por el artículo 260 CC, “los actos o contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad, o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial”. De esta manera, dichos actos o contratos no son nulos ni absoluta ni relativamente. Lo que se dispone, en verdad, no es más que una limitación de la responsabilidad individual del hijo, puesto que al decir que esos contratos lo obligan solo en su peculio profesional, se está diciendo que el hijo responde solamente hasta el monto de dicho peculio. La afirmación anterior se ve corroborada por lo dispuesto en el inciso 2 del mismo artículo que dispone: “Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro ordinario de dicho peculio) sin autorización escrita de las personas mencionadas. Y si lo hiciere, no será obligado por esos contratos, sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado”. Todo lo cual indica, que el acto no es nulo sino solamente inoponible al hijo en lo que exceda al monto indicado, con lo que se produce, en el fondo, otra limitación de la responsabilidad individual del hijo.

2.2.3 OTROS ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA DE CAPACIDAD

1. Incapacidades especiales o prohibiciones legales.

El último inciso del artículo 1.447 CC establece que, además de las incapacidades mencionadas, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Estas incapacidades especiales o particulares de que habla la ley, se encuentran establecidas para proteger a los incapaces o en consideración a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

Se ha discutido qué clase de incapacidad es la que establece el inciso en comentario. Avelino León H. estima que las incapacidades especiales a que se refiere el último inciso del artículo 1.447 CC son de goce y no de ejercicio, por cuanto constituyen prohibiciones que impiden la adquisición de ciertos derechos. Lo anterior, en la medida que la ley prohíba absolutamente la celebración del respectivo acto o contrato. Claro Solar entiende que se trata de una especie de incapacidades relativas, y por consiguiente, sólo de incapacidad de ejercicio. Arturo Alessandri sostiene que más que una incapacidad hay una prohibición, que acarrea la ilicitud del objeto y la nulidad absoluta de acto.

Ejemplos de esta clase de incapacidad:

- Art. 402 CC. Es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo, aun con previo decreto de juez.
- Art. 412 CC. Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.

5. Convenciones sobre capacidad.

Las convenciones sobre capacidad son nulas porque vulneran el orden público

2.3. LA NACIONALIDAD

1. Concepto

Nacionalidad: vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado. Impone derechos y deberes tanto al sujeto como al Estado.

Son chilenos los que la Constitución declara tales; los demás son extranjeros (Art. 56 CC).

2. Formas de adquirir la nacionalidad chilena

Artículo 10 CPR.- Son chilenos:

1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;

2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;

3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley,

4º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

Existen causales de pérdida de la nacionalidad. Pese a que la nacionalidad debe ser una, se permite la doble nacionalidad. (Art. 11 CPR)

Según el Art. 12 CPR, la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.

La ley no reconoce diferencias entre el chileno y extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla el CC (Art. 57 CC).

Art. 57 CC. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.

Pero hay ciertas excepciones y distinciones. Ej. No puede ser testigo de un testamento solemne un extranjero no domiciliado en Chile (Art. 1012 N° 10 CC); Sólo puede testar en el extranjero conforme a las formalidades del testamento otorgado en Chile el chileno o extranjero con domicilio en Chile

(Art. 1028 N°1); Protección a los chilenos en sucesión (Art. 988 CC); Se reserva a chilenos (por regla general, sólo personas naturales) la propiedad de determinados bienes raíces del territorio nacional (límites). Art. 6° DL 1939.

La ley chilena sigue al chileno en país extranjero en cuanto a obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia respecto de cónyuges y parientes chilenos (Art. 15 N°2 CC).

2.4. EL DOMICILIO

1. Concepto.

Domicilio: residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

Art. 59 CC. El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.
Divídese en político y civil.

2. Domicilio político y domicilio civil.

(1) Domicilio político: relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene es miembro de la sociedad chilena, aunque sea extranjero (Art. 60 CC). Según lo tenga o no, se dividen en domiciliados o transeúntes, lo que es importante ya que en los primeros se radican determinados derechos y obligaciones que a los segundos no les afectan.

Art. 60 CC. El domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero.
La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al Derecho Internacional.

Art. 61 CC. El domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado.

(2) Domicilio civil: se refiere a una parte determinada del territorio; es una determinación del domicilio político. Al domicilio civil corresponde mejor la definición legal de domicilio. Función: ubicación de la persona de manera regular para efectos jurídicos.

3. Elementos del domicilio.

- a) Físico: residencia.
- b) Psicológico: ánimo de permanecer en ella. Es el elemento más importante y también el más difícil de averiguar. Para determinar el ánimo cuando éste no aparece real (de manera inequívoca) el legislador recurre a presunciones

positivas o negativas a partir de hechos señalados en la ley.

4. Domicilio, residencia y habitación.

Hay que distinguir 3 conceptos:

- **Habitación o morada** : relación de hecho de una persona con un lugar donde permanece y generalmente pernocta, pero puede ser ocasional o transitoria.

Importancia:

- (i) la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso extranjeros. (Art. 14 CC)
- (ii) hace de domicilio si no se tiene nada más.

Residencia: permanencia física de una persona en un lugar determinado en forma permanente o habitual. No es ocasional, implica la idea de algo estable.

Importancia:

- (i) hace de domicilio si no se tiene en otro lado (Art. 68 CC),

Art. 68 CC. La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte.

- (ii) el impuesto a la renta deben pagarlo los domiciliados y residentes en Chile.

- **Domicilio**: intención de la persona de tener el lugar de su residencia como asiento de su vida social y jurídica.

5. Presunciones de domicilio.

Estas presunciones son simplemente legales, admitiendo prueba en contrario.

1. Presunciones positivas:

a) Art. 62 CC. "El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad." En el fondo es la norma general que reconoce la situación corriente de las personas en cuanto al domicilio.

b) Art. 64 CC: se presume el ánimo de permanecer en un lugar por el hecho de abrir en él tienda, fábrica, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona.

c) Art. 64 CC: rige la misma presunción por el hecho de aceptar en el lugar

un cargo concejal, un empleo fijo de los que regularmente se conceden por largo tiempo, u otras circunstancias análogas.

2. Presunciones negativas:

a) Art. 63 CC: no se presume el ánimo de permanecer por el sólo hecho de habitar un individuo casa propia o ajena, si se tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental. Por ejemplo, como la del viajero o aquel que ejerce una comisión temporal.

b) Art. 65 CC. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, quien ha sido confinado por decreto judicial a un paraje determinado o desterrado de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios.

6. Clasificación del domicilio.

Además de la distinción entre domicilio político y civil, se distingue:

1. General y especial:

a) Domicilio general: el normal de una persona para todas sus relaciones jurídicas.

b) Domicilio especial: se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas. Es generalmente convencional. Excepciones donde es legal: Art. 2350 CC a propósito de la fianza.

2. En atención al origen: legal, convencional y real.

a) Domicilio legal: el impuesto por la ley a determinadas personas, en atención a su situación de dependencia respecto de otros o al cargo que desempeñan. Ej. Los menores que viven bajo patria potestad tienen el domicilio paterno o materno, según el caso (Art. 72 CC). Se presume el domicilio por el hecho de aceptarse en el lugar un cargo concejal o un empleo fijo (Art. 64 CC).

Art. 64 CC. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar... por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejal, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas”.

Art. 72 CC. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno o materno, según el caso, y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador.

b) Domicilio convencional: en un contrato se puede establecer, de común acuerdo, un domicilio civil especial para los actos judiciales y extrajudiciales a que dé lugar el contrato (Art. 69 CC). Es limitado tanto en la materia como en el tiempo. Es unilateralmente inmutable mientras dure el contrato. Pero existe una subsistencia general del domicilio en todo contrato, aplicable también al domicilio real (Art. 1589 CC: si el acreedor o deudor cambia de domicilio, el pago se realiza en el original).

Art. 69 CC. Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato.

Art. 1589 CC. Si hubiere mudado de domicilio el acreedor o el deudor entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre éste en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa.

c) Domicilio real: norma general, corresponde a la definición legal de domicilio. El cambio de domicilio se produce cuando hay un cambio real y efectivo de sus elementos constitutivos.

Prueba del domicilio (real): como existe la presunción del Art. 62 CC, debe probar el domicilio quien alega su falsedad o cambio; o el interesado si se le asigna uno que no es verdadero o ha sido cambiado. Se admiten todos los medios probatorios.

Art. 62 CC. El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.

No siempre el cambio de domicilio tiene efectos jurídicos, como sucede respecto del pago en un contrato (Art. 1589 CC) o en relación al juicio (Art. 49 CPC referido al domicilio designado en la primera gestión judicial).

7. Pluralidad de domicilios.

El CC la acepta, lo que concuerda con la posibilidad de tener un domicilio convencional (que puede ser ficticio). Puede tener especial importancia respecto a las personas jurídicas. Art. 67 CC.

Art. 67 CC. Cuando concurren en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo.

9. Importancia del domicilio.

1. Fija para las personas el lugar donde habitualmente deben ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Ej. Pago entre deudor y acreedor (Arts. 1587 a 1589 CC).
2. Determina el lugar en que se abre la sucesión y la ley aplicable a ella (Art. 955 CC).
3. En materia procesal, es importante para determinar la competencia (Art. 134 COT).
4. La posesión notoria de estado civil debe haberse desarrollado ante el vecindario del domicilio (Art. 200 y 310 CC).
5. Las inscripciones en el Registro Conservatorio o en el Registro civil deben consignar el domicilio de las partes o comparecientes.

2.5. EL ESTADO CIVIL

1. Concepto.

Art. 304 CC. El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.

Esta definición es deficiente porque:

1. No señala a qué calidad se refiere.
2. La habilidad a que se refiere puede ser muy diversa, aunque el estado civil permanezca invariado. Por ejemplo un mayor de edad, soltero tiene plena capacidad de ejercicio pero si cae en demencia su capacidad desaparece, aunque no varíe su estado civil.

Por esto, se define el estado civil como la calidad permanente que un individuo ocupa en la sociedad y derivada de sus relaciones de familia. No es exacto que sea permanente, pues puede variar.

2. Características.

1. El estado civil es uno e indivisible en cuanto se atienda a una sola clase de relaciones de familia (en cuanto a su fuente): filiación, matrimonio o acuerdo de unión civil. Por ejemplo, atendiendo al matrimonio, se es soltero, casado o viudo; y ahora con la ley de matrimonio civil se agrega el estado civil de divorciado.
2. El estado civil da origen a derechos y cargas u obligaciones. Por ejemplo obligaciones patrimoniales entre los padres y los hijos y entre cónyuges.
3. Todo lo relativo al estado civil es de orden público; su regulación escapa a la autonomía de la voluntad particular. Por ejemplo aunque el matrimonio es un acto voluntario, las consecuencias que de él se derivan están establecidas en la ley, salvo las escasas estipulaciones posibles en las capitulaciones matrimoniales (Art.1715 CC).
4. El estado civil es personalísimo. Es por ello que:
 - a) En los actos de estado civil no se admite representación legal, sino sólo voluntaria.
 - b) Las acciones judiciales para adquirirlo o protegerlo son estrictamente personales: son intransferibles, intransmisibles e intransables (Art. 2450 CC).
 - c) Ciertos derechos patrimoniales inherentes a los estados civiles son inembargables. Ej. Usufructo del padre sobre los bienes del hijo (Art. 2466 CC).
5. El estado civil es imprescriptible, ya que el artículo 2498 CC dice que se gana por prescripción el dominio de los bienes que están en el comercio

humano. Además del argumento del artículo 320 CC.

6. Es inherente toda persona natural; no son materia de arbitraje (Art. 230 y 357 N°4 COT), es permanente (no se pierde mientras no se sustituya por otro).

3. Fuentes del estado civil.

- 1) La ley: por ejemplo, el estado civil de hijo lo tiene aquel cuya filiación se haya determinado en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I del Código Civil.
- 2) La voluntad de las partes: por ejemplo, las personas que contraen matrimonio adquieren el estado civil de casados. Las personas que celebran el acuerdo de unión civil adquieren el estado civil de convivientes civiles. La ocurrencia de un hecho, por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges hace adquirir al otro el estado civil de viudo.
- 3) La sentencia judicial, por ejemplo, la sentencia judicial que declara el divorcio de los cónyuges hace adquirir a éstos el estado civil de divorciados.

En la constitución del estado civil sirven de base todos los hechos que derivan de las relaciones de familia y del parentesco, básicamente dichos hechos son los siguientes: nacimiento, muerte, matrimonio y acuerdo de unión civil.

4. La familia y el parentesco.

Las relaciones de filiación, matrimonio y acuerdo de unión civil dan origen al parentesco.

Familia: conjunto de personas unidas por un lazo de parentesco, matrimonio o acuerdo de unión civil.

El parentesco puede ser:

1. Por consanguinidad: se produce entre dos personas que descienden una de otra o tienen un antepasado común (Art. 28 CC).

Art. 28 CC. Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.

2. Por afinidad: se produce entre una persona que está o ha estado casada, o como conviviente civil producto de un acuerdo de unión civil y los consanguíneos de ésta (Art. 31 inc. 1º CC).

Art. 31 CC. Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer.

La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos de su mujer".

En el parentesco hay que distinguir:

- a) Línea: serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta), o de un antepasado común sin descender uno del otro (línea colateral). (Art. 27 inc. 2º CC)
- b) Grado: número de generaciones que separan a los parientes (Art. 27 inc. 1º CC). Así, el padre es pariente de primer grado en la línea recta del hijo y de segundo grado en la línea recta del nieto.

En el parentesco colateral, es necesario encontrar al ascendiente común y subir hasta él para bajar después hasta el otro pariente. Así, por ejemplo, dos hermanos son parientes en segundo grado y dos primos lo son en cuarto grado.

Art. 27 CC. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal.

¿Hasta qué grado podemos considerar que los colaterales son parientes? La ley no da una respuesta directa, pero en las reglas de la sucesión intestada se establece que hasta el sexto grado (los que en lenguaje corriente son primos de segundo grado, Art. 992 regla 2ª CC). Se considera iguales a los colaterales de simple conjunción (parientes por parte de madre o de padre) y los de doble conjunción (por parte de madre y de padre).

La línea y el grado de afinidad con un consanguíneo del marido o la mujer, se califican por la línea y grado de consanguinidad del dicho marido o mujer con ese consanguíneo (Art. 31 inc. 2º CC).

Es preciso señalar que los cónyuges no son parientes afines entre sí, ya que no quedan comprendidos en el Art. 31 CC. Esto se demuestra en los Arts. 15 N°2 y 353 inc.3 del Código Civil. Lo mismo ocurre con los convivientes civiles del acuerdo de unión civil, donde solo se les trata así para efectos del art. 42 CC (audiencia de parientes).

5. Importancia del parentesco.

1. Genera derechos y obligaciones entre los padres y los hijos (Título IX Libro I CC).
2. Genera el deber de alimentos frente al cónyuge y parientes (Art. 321 CC).
3. Determina quiénes son llamados a la guarda legítima de una persona (Art. 367 CC).
4. Los órdenes de sucesión (en la sucesión intestada) se establecen en atención a la cercanía del parentesco.
5. Con anterioridad a la ley 21.515, del año 2022, el parentesco servía para determinar quiénes deben dar el ascenso para el matrimonio (Art. 107 CC, artículo actualmente derogado).
6. Determina impedimentos para contraer matrimonio (Art. 6º LMC).
7. Hay disposiciones que se refieren al parentesco en puntos específicos. Ej. Es nula la compraventa entre el padre y el hijo.

6. Efectos del estado civil.

Los efectos que produce el estado civil son los derechos y obligaciones que de él derivan. Estos efectos son de orden público, los señala la ley, sin que juegue en esta materia el principio de la autonomía de la voluntad. Ejemplo: del estado civil de casado derivan los derechos-deberes de fidelidad, ayuda mutua, socorro, etc.; y del estado civil de padre derivan los derechos-deberes de la autoridad paterna, la patria potestad, el derecho de alimentos, los derechos hereditarios, etc.

7. Prueba del estado civil.

La prueba del estado civil está sometida a reglas especiales que el Código Civil establece en los artículos 304 a 313, que deben aplicarse con preferencia a las contenidas en el Título XXI del Libro IV "De la Prueba de las Obligaciones", sin perjuicio de que ellas se apliquen en aquellas materias no previstas en las reglas particulares sobre la prueba del estado civil.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.585, la situación en cuanto a la prueba del estado civil es la siguiente:

a) Existen medios de prueba principales, constituidos por las partidas (Art. 305 CC).

b) A falta de partidas, se admite una prueba supletoria, distinguiéndose entre la prueba del matrimonio (artículo 309, inciso 1º CC) y la prueba de la filiación (artículo 309 inciso 2 CC). Todo lo dicho sobre la prueba del matrimonio aplica de idéntica manera al Acuerdo de Unión Civil.

Medios de prueba principales:

Los medios de prueba principales, como señalamos anteriormente, están constituidos por las respectivas partidas del Registro Civil.

El estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado, o viudo, y de padre, madre o hijo, se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, y de nacimiento o bautismo.

El estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación.

La edad y la muerte podrán acreditarse o probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte.

Esta disposición emplea las formas verbales “acreditará” y “probará” en forma diferenciada. Con esto se quiere significar que las partidas cumplen una doble función:

- 1) Sirven de prueba de la filiación en juicio, y
- 2) Sirven de medio de acreditar una filiación determinada ante cualquier requerimiento del quehacer jurídico.

Medios de prueba supletorios:

Respecto a los medios de prueba supletorios del estado civil, es menester distinguir las siguientes situaciones:

1) Prueba supletoria del matrimonio:

De acuerdo al inciso 1º del artículo 309 CC, “la falta de la partida de matrimonio podrá suplirse por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil”.

En consecuencia, a falta de la partida de matrimonio, este medio de prueba

principal puede ser reemplazado:

(a) Prueba del matrimonio por otros documentos auténticos: En general la doctrina ha entendido que cuando el artículo 309 CC hace referencia a "otros documentos auténticos", se está refiriendo a otros instrumentos públicos, puesto que el artículo 1699 CC, al definir el instrumento público, equipara ambos términos (Somarriva). Ejemplo: una inscripción de defunción que deje constancia que el difunto era casado con una persona determinada. Una doctrina minoritaria estima que la ley no ha determinado, en forma alguna, la clase de los otros documentos auténticos que puedan usarse para suplir la falta de partidas, y exige solamente que sean auténticos (Fueyo).

(b) Prueba del matrimonio por testigos presenciales: El artículo 309 del Código Civil admite también como medio supletorio "la declaración de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio". Por tanto, se exigen testigos presenciales, quedando excluidos los testigos de oídas.

(c) Prueba del matrimonio por la posesión notoria: Finalmente, según el mismo artículo 309 CC también es procedente la prueba de la posesión notoria del matrimonio. Este medio de prueba consiste en gozar del estado civil a la vista de todos, en forma pública, y sin protesta o reclamo de nadie. De acuerdo al artículo 310 CC, la posesión notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente: 1) en haberse tratado los supuestos cónyuges como tales en sus relaciones domésticas y sociales (nombre y trato); y 2) en haber sido uno de los cónyuges recibido en ese carácter por los deudos y amigos del otro, y por el vecindario de su domicilio en general (fama). Según lo preceptuado en los artículos 309 a 313 CC, los requisitos de la posesión notoria para que sirva de prueba del estado civil de casado son los siguientes:

- La posesión tiene que ser pública, no clandestina.
- Debe ser continua.
- Debe haber durado diez años continuos a lo menos (Art. 312 CC)

Debe haberse probado en la forma indicada en el artículo 313 CC. El artículo 313 CC establece que "la posesión notoria del estado de matrimonio se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse".

2) Prueba supletoria de la filiación:

La filiación, a falta de partida o subinscripción, sólo podrá acreditarse o probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya

determinado legalmente. A falta de éstos, el estado de padre, madre o hijo deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el Título VIII del Libro I del Código Civil (artículo 309, inciso 2º CC). De manera que a falta de partida o subinscripción, la filiación, matrimonial o no matrimonial, sólo podrá probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado. Ejemplo: se puede probar el estado civil de hijo con los documentos que señale el artículo 187 del CC, esto es, por acta extendida ante cualquier Oficial del Registro Civil, por escritura pública o testamento en que se haya verificado el reconocimiento; o con el acta en que conste la confesión de paternidad o maternidad en el reconocimiento voluntario provocado. A falta de estos instrumentos auténticos, según la ley, el estado civil de padre, madre o hijo sólo podrá probarse en el correspondiente juicio de filiación, en la forma y con los medios previstos en el Título VIII del Libro I del Código Civil.

8. Sentencias en materia de estado civil.

La regla general es que las sentencias judiciales sólo produzcan efectos entre las partes que han litigado (artículo 3º, inciso 2º CC). Esta regla sufre una importante excepción en el caso de sentencias que declaran verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, pues el artículo 315 CC señala que tales fallos no sólo valen respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea.

Esta excepción tiene el alcance que la misma norma señala, es decir, rige exclusivamente para los juicios de reclamación e impugnación de paternidad o maternidad. Así lo señala este precepto cuando hace referencia al Título VIII del Libro I del Código Civil, que se refiere a las acciones de filiación, lo que queda confirmado con el artículo 317 del CC que precisa quiénes son los legítimos contradictores en esos juicios. Es necesario tener presente que la regla del artículo 315 del CC, como señala el profesor René Ramos Pazos, "sólo se aplica a los juicios constitutivos de estado civil, y no a aquellos otros de carácter patrimonial, en que la filiación sólo sirve de fundamento a la acción".

El artículo 316 CC señala los requisitos que deben cumplirse para que los fallos a que se refiere el artículo 315 del mismo cuerpo legal produzcan estos efectos absolutos. Dichos requisitos son los siguientes:

- 1) Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada: La cosa juzgada es el efecto que la ley atribuye a las sentencias firmes y ejecutoriadas por considerarlas como expresión de la verdad. Debe darse la triple identidad de la cosa juzgada.
- 2) Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor: Según el inciso 1º del artículo 317 CC, "legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la

cuestión de maternidad el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo". La norma agrega, en su inciso 2º, que "son también legítimos contradictores los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y, también, los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla". La norma del artículo 317 del CC debe concordarse con los artículos 206, 207, 213 y 216 del mismo Código, que establecen los casos en que los herederos del padre o madre pueden entablar las acciones de reclamación o de impugnación de paternidad o maternidad o ser demandados en su calidad de herederos del padre o madre, respecto de esas mismas acciones. En esta materia, el artículo 318 CC establece que "el fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de los herederos aprovecha o perjudica a los coherederos que citados no comparecieron". De modo que si fallece el legítimo contradictor durante la contienda, es necesario citar a sus herederos, para continuar con la tramitación del juicio.

- 3) Que no haya habido colusión en el juicio: Esto significa que las partes no deben haberse puesto de acuerdo, o sea, el fallo debe haberse obtenido legítimamente. Al respecto, el artículo 319 CC señala que "la prueba de colusión en el juicio no es admisible sino dentro de los cinco años subsiguientes a la sentencia".

9. El Registro Civil (Ley N° 4.808).

Las inscripciones de los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos y contratos relativos al estado civil se deben hacer en el Registro Civil, que tiene 4 libros:

1. Libro de Nacimientos: en él se anotan los nacimientos, la repudiación, la emancipación, etc.
2. Libro de Matrimonios: sólo los matrimonios.
3. Libro de Defunciones: las defunciones y las sentencias de muerte presunta.
4. Libro de Registros especiales de Acuerdos de Unión Civil: sólo los acuerdos celebrados.

Además, deben subinscribirse las sentencias ejecutoriadas que dispongan la rectificación de cualquier partida. Ej. En el registro de matrimonios se subinscriben los instrumentos y sentencias que alteren el régimen de bienes.

Sobre los certificados o partidas

- Art. 306 CC. Se presumirán la autenticidad y pureza de los documentos antedichos, estando en la forma debida.

- Art. 17 CC. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. La forma se refiere a las

solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.

- Art. 307 CC. Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando conste su autenticidad y pureza, probando la no identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere y la persona a quien se pretenda aplicar.
- Art. 308 CC. Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. Podrán, pues, impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata.
- Las partidas no prueban directamente el estado civil, sino sus hechos constitutivos.
- Estos certificados son instrumentos públicos (Art. 24 Ley 4.808 sobre Registro Civil)

2.6 EL PATRIMONIO³

1. Concepto.

Patrimonio: conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación pecuniaria, alcanzando bienes presentes y futuros.

En consecuencia, en el patrimonio no sólo entran los derechos, los bienes, los créditos sino también las deudas. Cuando estas últimas, en un momento dado, son más que las relaciones activas, se dice que el patrimonio tiene un pasivo mayor que el activo.

En el patrimonio sólo entran los derechos que pueden apreciarse económicamente; los que no admiten semejante estimación quedan fuera, y por eso se llaman extrapatrimoniales. Tienen este carácter, por ejemplo, los derechos políticos, los derechos de la personalidad, los derechos de familia. Todos ellos en sí mismos carecen de valor pecuniario, sin perjuicio de que el daño que derive de su violación sea indemnizable en dinero.

2. Activo bruto, pasivo y activo neto del patrimonio.

La suma de todos los elementos positivos del patrimonio (bienes y derechos de valor pecuniario) forman su activo bruto y la suma de todos sus elementos negativos (deudas y cargas pecuniarias) constituyen su pasivo. Cuando el activo es mayor que el pasivo, la diferencia recibe el nombre de activo neto.

Por ejemplo, si una persona tiene bienes que en total valen 20 millones de pesos y deudas que suman 6 millones de pesos, el activo neto es igual a 14 millones de pesos.

Una minoría de autores identifica el patrimonio con el activo bruto.

3. Utilidad del concepto de patrimonio.

1) El concepto de patrimonio es el que hace posible la responsabilidad del deudor por sus obligaciones civiles.

De acuerdo al derecho de prenda general de los acreedores (Art. 2465 CC), el deudor responde de sus obligaciones no con los bienes que tuvo al tiempo de contraerlas, sino con los bienes que existan en su patrimonio al tiempo de exigirse el pago. Esto ocurre porque es el patrimonio el que responde (no en sí mismo, sino sus bienes). Por lo mismo, los acreedores no pueden perseguir los bienes que han salido del patrimonio, salvo en el caso de la

³ Texto base: Tratado de Derecho Civil: Partes Preliminar y General. Autores: Arturo Alessandri Rodríguez, Manuel Somarriva Undurraga y Antonio Vodanovic H. Pág. 476 y siguientes.

acción pauliana (Art. 2468 CC), y los créditos no pueden hacerse valer en un patrimonio distinto del obligado. La responsabilidad del patrimonio se ejerce indistintamente sobre los bienes que contenga, no sobre bienes determinados. Cuando hay garantías reales, puede perseguirse en primer término el bien gravado, pero si no alcanza, el saldo se hace efectivo indeterminadamente sobre los demás bienes.

2) El concepto de patrimonio hace concordante y orgánica la regulación de la sucesión por causa de muerte.

En nuestro ordenamiento el patrimonio es transmisible; pasa del causante a sus herederos, lo que está establecido en los Arts. 951 y 1097 CC.

3) El fundamento de la personalidad jurídica adquiere, a través del concepto de patrimonio, una base y explicación coherentes.

El que la propiedad y responsabilidad puedan radicarse exclusivamente en una persona jurídica y no en los miembros que la componen, no puede explicarse jurídicamente sino en virtud de que ella tiene un patrimonio propio distinto del patrimonio personal de sus miembros.

4) La teoría del patrimonio explica la figura jurídica de la representación.

Si el representante actúa por el representado, los efectos del acto se van a radicar en éste y no en la persona que materialmente está actuando, es decir, el patrimonio vinculado es el del representado.

5) El patrimonio, dada su naturaleza, sirve también para explicar el fenómeno de la subrogación real

Consiste en la sustitución de una cosa por otra en términos tales que la nueva pasa a ocupar jurídicamente, el mismo lugar que la antigua. La cosa que sustituye, sin cambiar de naturaleza, queda colocada dentro del patrimonio en la misma situación jurídica que tenía la cosa sustituida. Por ejemplo, si un bien raíz se incendia, pasa a ser reemplazado en el patrimonio por la indemnización que pague la compañía aseguradora. Ahora bien, la subrogación se explica por el carácter de universalidad de derecho que, según la teoría clásica, tiene el patrimonio y que permite la mutación de los elementos constitutivos de éste, sin que por ello se altere el conjunto unitario formado por los mismos.

4. Teoría clásica.

Nuestro Código Civil, al igual que el francés, no formula en ningún título o párrafo una teoría general sobre el patrimonio, aunque muchas normas diseminadas de uno y otro cuerpo legal se refieren a éste y le aplican principios

que la doctrina ha sistematizado. Nuestro Código Civil habla, por ejemplo, del patrimonio del desaparecido (Art. 85 CC), de las fuerzas y obligaciones de los patrimonios (Arts. 1066, 1170 y 1744 CC), de la separación de patrimonios (Art. 1170 y 1382 CC), etc.

De acuerdo a la teoría clásica, diseñada en el siglo XIX por los franceses Aubry y Rau, el patrimonio está compuesto de relaciones activas y pasivas, es decir, de derechos y obligaciones o deudas susceptibles de valoración económica. Los derechos constituyen el elemento activo, el haber del patrimonio, y las obligaciones o deudas su elemento pasivo.

Una opinión minoritaria sostiene que sólo lo contienen los activos.

Quedan fuera del patrimonio los derechos y deberes que no admiten una valuación en dinero. Pero estos derechos y deberes extrapatrimoniales, junto con el patrimonio, entran en una noción más amplia que suele llamarse la esfera jurídica de la persona. Y así, por ejemplo, el derecho de propiedad está en el patrimonio y en la esfera jurídica de su titular; pero el derecho a la vida y el derecho a sufragio no están en el patrimonio, aunque sí en la esfera jurídica del individuo.

5. Características del patrimonio según la teoría clásica.

Para la teoría clásica, el patrimonio es una emanación de la personalidad. Del principio que liga el patrimonio a la personalidad derivan las demás características que la teoría clásica atribuye al patrimonio:

- a) Toda persona, sea física o jurídica, tiene un patrimonio.
- b) El patrimonio no es transferible, aunque, sí, es transmisible por sucesión, a la muerte de su titular.
- c) Sólo las personas pueden tener un patrimonio.
- d) Una misma persona no puede tener sino un patrimonio, que es uno e indivisible como la persona misma.

En consecuencia, el patrimonio sería único, inalienable, imprescriptible, inembargable e intransmisible (en nuestro derecho es transmisible).

6. Teoría objetiva. El patrimonio – fin o de afectación.

En contra de la teoría clásica del patrimonio que considera a éste como un atributo y emanación de la personalidad, surgió la teoría objetiva del patrimonio-fin o patrimonio de afectación. De acuerdo a ella, el patrimonio es

sólo una masa de bienes y no se encuentra indisolublemente unido a la personalidad. La cohesión y unidad de los elementos del patrimonio no arranca de la voluntad de la persona sino del fin o destino a que está afecto el conjunto de bienes. La afectación a determinado fin justifica la existencia y razón de ser del patrimonio. De esta idea central síguese la posibilidad de patrimonio sin titulares y la de que una sola persona pueda tener varios patrimonios.

Crítica a la teoría: Se dice que es exagerada al despersonalizar el patrimonio hasta el extremo de concebir que las cosas agrupadas podrían tener por sí mismas derechos y, en cierto modo, voluntad propia.

7. El patrimonio general ¿es una universalidad de derecho?

Algunos afirman que el patrimonio general de las personas es una universalidad jurídica, llamada también de derecho.

Advirtamos que en un sentido genérico por universalidad se entiende un conjunto de bienes que forman un todo.

Tradicionalmente se distingue entre universalidades de hecho y universalidades de derecho. Es muy delicado y ha suscitado controversias el tema del elemento que diferencia mutuamente las dos categorías.

Se dice que debiera acogerse la idea de que las universalidades de hecho son un complejo de cosas, homogéneas (por ejemplo, una biblioteca) o heterogéneas (por ejemplo, un establecimiento de comercio) reunidas conjuntamente por voluntad del ser humano en razón del destino, o sea, de una relación funcional. Por el contrario, la universalidad de derecho consiste en un complejo orgánico (creado por ley) de relaciones jurídicas activas y pasivas, reunidas por la pertenencia de un mismo sujeto o (siempre en su estructura unitaria) a una pluralidad de sujetos. Por ejemplo; es una universalidad de derecho el patrimonio hereditario, en el cual se enfrentan elementos activos y pasivos, reunidos por un destino, en el sentido de que aquellos elementos activos deben servir para la satisfacción de las obligaciones pasivas y no de otras.

La doctrina francesa expresa que el patrimonio general, sea de una persona viva o muerta, es el prototipo de la universalidad jurídica o de derecho.

En cambio, la doctrina italiana, sostiene que el patrimonio no es una universalidad, porque toda universalidad, de hecho o de derecho, es una cosa, y el patrimonio de una persona viva no lo es y por eso no se puede adquirir ni enajenar mediante acto jurídico entre vivos. Sólo la sucesión o patrimonio de una persona muerta es una cosa, una universalidad jurídica, y por ser una cosa pueda adquirirse y enajenarse mediante un acto entre vivos.

8. Patrimonios separados.

Se dice que hay patrimonios separados cuando dos o más núcleos patrimoniales, mutuamente independientes entre sí, tienen por titular a un mismo sujeto.

Como resulta de la definición, se trata de masas o núcleos patrimoniales que la ley crea –y no los particulares– para someterlos a un régimen jurídico propio que esa misma ley juzga adecuado o conveniente.

Algunos ejemplos:

- En la sociedad conyugal se diferencian: el patrimonio común o social, el patrimonio propio del marido, el patrimonio propio de la mujer y el patrimonio reservado de la mujer casada (masa de bienes que se forma cuando la mujer ejerce o ha ejercido un empleo, oficio o profesión, industria o comercio separado de su marido, constituida por los bienes que obtenga o haya obtenido con dicho ejercicio y lo que con ellos adquiera durante la vigencia del matrimonio).
- El hijo de familia menor adulto sometido a patria potestad tiene un patrimonio general que se lo administra el padre, madre o ambos y puede tener un peculio profesional o industrial (masa de bienes que se forma con lo adquirido por el hijo con su trabajo y cuyo goce y administración le corresponde a él mismo)
- Se menciona también como caso de patrimonio separado el que resulta de la separación de los bienes del difunto respecto de los del heredero, beneficio que pueden pedir los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios y en virtud del cual ellos tienen derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero.
- También se señala como un caso de separación patrimonial el que deriva del beneficio de inventario, en cuya virtud no se hace responsables, a los herederos que aceptan de esta forma, de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Algunos afirman que este no es un caso de dualidad de patrimonios, sino de limitación de la responsabilidad.

9. Patrimonios autónomos.

Patrimonio autónomo es aquel que transitoriamente carece de sujeto.

El interés práctico de la institución es la conservación del patrimonio y, además, evitar que sea abandonado mientras advenga un titular o sean empleados los bienes que lo forman.

Ejemplos de patrimonios autónomos:

- Herencia yacente.
- El que representa la asignación de crear una fundación.

CAPÍTULO 3. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

3.1 CUESTIONES GENERALES

1. Concepto.

Son aquellos que tienen por fin defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También se dice que son aquellos derechos que toda persona física, en la calidad de sujeto jurídico, lleva inseparablemente desde su origen y que no tienen otro presupuesto que la existencia de la persona.

Solamente a partir de mediados del Siglo XX, y en especial por influencia del Código Civil italiano de 1942, la civilística agregó a los "atributos" tradicionales los llamados "derechos de la personalidad", denominados también por algunos "jus in se ipsum" (derechos sobre sí mismo): derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, derecho al honor, derecho a la libertad, derecho a la actividad vital y al trabajo, derecho a la privacidad o intimidad, derecho a la identidad personal, derecho a disponer de partes separadas del cuerpo, etc. Estas características corresponden en general, dentro del ámbito del Derecho Civil, a las que ya había encontrado el Derecho Público para definir a las personas dentro de su especialidad. Los derechos de la personalidad "no son más que el resultado de la privatización de los derechos públicos subjetivos, que la mayoría de las Constituciones Políticas acogieron primeramente bajo el nombre de "garantías constitucionales" y que se conocen hoy con la denominación de "derechos humanos".

En la actual evolución jurídica, una persona natural se encuentra resguardada por los derechos humanos que contemplan las Constituciones Políticas y los Tratados Internacionales en vigencia en el país de que se trate, por los derechos protegidos por el ordenamiento penal, así como por los derechos y atributos de la personalidad contemplados en la legislación civil. En el fondo, se trata del mismo objeto de protección, según las diversas perspectivas jurídicas involucradas⁴.

2. Debate sobre la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad.

Algunos afirman que los derechos de la personalidad no pueden configurarse como verdaderos derechos subjetivos porque todo derecho subjetivo entraña como elementos distintos el sujeto y el objeto del mismo y en los derechos de la personalidad aparecen confundidos, como un solo ente. Otros, refutando, manifiestan que el objeto de los derechos de la personalidad es un ente distinto de la persona, aunque tiene carácter personal: la vida, el honor, la

⁴ "Los derechos de la personalidad en general: Concepción traicional", Gonzalo Figueroa Yáñez. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XIX.

integridad física.

El hecho es que los derechos de la personalidad protegen supremos intereses humanos y son considerados por la doctrina y las legislaciones positivas.

3. Protección constitucional de los derechos de la personalidad.

Muchas Constituciones Políticas dan cabida en sus textos a varios derechos de la personalidad. De esta manera se pueden hacer valer contra los poderes públicos del Estado que pretendan vulnerarlos, y no sólo contra los particulares que pretendan desconocerlos a otros particulares.

La Constitución Política de Chile de 1980 asegura el derecho a la vida, a la integridad física de la persona; el derecho al respeto de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia; el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; el derecho a la libertad del trabajo y el derecho a su libre elección, y el derecho de propiedad intelectual, artística e industrial.

Estos derechos consagrados en el Art. 19 de la Constitución Política de la República y otros que taxativamente se señalan pueden defenderse, entre otros medios, por la acción de protección (Art 19 N°20 CPR).

4. Naturaleza y caracteres de los derechos de la personalidad.

De acuerdo a la escuela de Derecho Natural, los derechos de la personalidad derivan de la propia naturaleza humana y son preexistentes a su reconocimiento por el Estado pero su efectividad emana del reconocimiento de éste.

Como caracteres de los derechos de la personalidad se mencionan los siguientes:

- 1) Son generales, porque todas las personas, por el simple hecho de serlo, se constituyen en sus titulares.
- 2) Son absolutos, porque se respeto puede imponerse a todos los demás sujetos.
- 3) Son extrapatrimoniales, es decir, en sí mismos no son valuables en dinero. Por ejemplo, nadie puede decir que el derecho a la vida admite una estimación pecuniaria. Cuestión distinta es que el daño surgido como consecuencia de la violación de un derecho de la personalidad sea indemnizable en dinero. En este caso no se avalúa el derecho sino el daño que provoca la infracción.
- 4) Son esenciales, porque nunca pueden faltar. El ser humano desde que nace los tiene y sólo se extinguen con su muerte.

- 5) Son indisponibles, es decir, no pueden renunciarse, cederse, transmitirse ni transigirse.
- 6) Son imprescriptibles, o sea, no se pierden por el no uso.

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

La doctrina presenta variadas clasificaciones de los derechos de la personalidad, pero ninguna los agota, pues son numerosos y son susceptibles de cambio por la evolución política y cultural de la sociedad.

I. Derechos a la individualidad.

1. Derecho a la integridad física que implica la protección de la vida y de la integridad corporal (Art. 19 N° 1 CPR). Los atentados a estos derechos constituyen delitos penados por el CP (como por ejemplo, el delito de homicidio, de lesiones, la ayuda e instigación al suicidio) pero si no llegan a ser constitutivos de delito, constituyen generalmente un hecho culpable que determinará la existencia de un cuasidelito civil.
2. Derechos que dicen relación con la libertad: son derechos que tiene el individuo con relación al Estado.
 - a) Derecho a la libertad misma (Art. 19 N° 7 CPol). El CP tipifica ciertos delitos que se pueden cometer contra la libertad de otros.
 - b) Derecho de reunirse y asociarse (Art. 19 N° 13 y 15 CPol).
 - c) Derecho de pensar, opinar y creer (Art. 19 N° 6 y 12 CPol).
 - d) Derecho de residir y trasladarse (Art. 19 N° 7 CPol).
 - e) Libertad de trabajo (Art. 19 N° 16 CPol).
 - f) Derecho a la "intimidad privada" (Art. 19 N° 4 y 5 CPol).

II. Derechos a la personalidad civil.

1. Derecho al nombre: derecho subjetivo que una persona tiene de usar su nombre y oponerse a su usurpación o uso indebido por parte de terceros. La usurpación del nombre es un delito penal (Art. 214 CP).
2. Derecho al estado civil: también hay delitos penales que lo protegen, como la usurpación del estado civil y la ocultación o sustitución de una persona para hacerla perder el estado. Además, está protegido por diversas acciones civiles: acciones de reclamación de estado, acciones de contestación de estado. Finalmente, hay sentencias constitutivas de estado.
3. Derecho a la propia imagen: se ha considerado que la reproducción de los rasgos de una persona sin su consentimiento es una acción culpable. Pero esto ha tenido que ser limitado por consideraciones como la libertad de información,

el lugar en que se toma la fotografía, etc.

III. Derechos a la personalidad moral.

Implica la protección del honor, la reputación e incluso los sentimientos de afección.

El Art. 19 N° 4 de la Constitución protege la vida privada y la honra de la persona y su familia. Esto es más amplio que los delitos penales contra el honor (calumnia e injuria).

Según el Art. 2331 CC, que estudiaremos a propósito de la Responsabilidad Extracontractual, estos delitos no dan lugar a indemnización, a menos que se pruebe el daño emergente o lucro cesante, lo que es una norma anacrónica y debiera ser suprimida. Al respecto, existen numerosos procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conocidos en Chile por el Tribunal Constitucional. Asimismo, dicho tribunal inició un procedimiento de oficio para declarar la norma inconstitucional, cuestión que finalmente se resolvió de manera negativa por el mismo tribunal.

La protección de los sentimientos de afección se refiere al daño moral, cuya indemnización es aceptada hoy en día tanto en materia contractual como extracontractual.

Por último, es necesario mencionar el derecho a la identidad de género, que fue consagrado por la ley 21120, promulgada el 28 de Noviembre de 2018, y entrada en vigencia el 27 de Diciembre de 2019. La ley define identidad de género como la "convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento" (art. 1 incº2). El mismo artículo faculta a aquellas personas cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral para pedir que se modifiquen en concordancia.

CAPÍTULO 4. LAS PERSONAS JURÍDICAS

4.1 CUESTIONES GENERALES

1. Origen.

El sistema jurídico ha debido reconocer, junto a la existencia de las personas naturales, la existencia de otros entes denominados personas jurídicas, de modo de hacer más fluidas las relaciones jurídicas.

Las personas naturales deben unirse a otras para progresar, aspirar al bien común. Puede ocurrir que un conjunto de personas formen un todo orgánico, que comienza a demostrar su propia individualidad, diferente de la de cada uno de sus integrantes. Se formará así un nuevo ente, capaz de contraer derechos y obligaciones, denominado persona jurídica.

2. Concepto.

Savigny, define a las personas jurídicas como seres creados artificialmente, capaces de poseer bienes, de tener patrimonio. El jurista alemán, los concibe como una ficción teórica que nuestro Código recepciona en su artículo 545, cuyo tenor es el siguiente:

Art. 545 CC. Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones.

Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados. Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.

3. Elementos esenciales.

Son dos:

1) Elemento material, esto es, un conjunto de personas o bienes con una finalidad común.

2) Elemento ideal, esto es, reconocimiento explícito por parte de la autoridad de su individualidad, de su capacidad de actuar en el mundo jurídico.

4.2 NATURALEZA JURÍDICA

Discutida en la doctrina, hay teorías que aceptan y otras que niegan las personas jurídicas.

I. Teorías que la aceptan.

1) Teoría de la ficción, postula que solo existen las personas naturales, siendo las personas jurídicas entes ficticios. Esta teoría parte del supuesto que el derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad y que en tal sentido solo un ser humano puede ser naturalmente sujeto de derechos. Sin embargo, agrega Savigny, el derecho positivo puede modificar esta regla natural y considerar la capacidad jurídica en relación con otros seres ficticios a los cuales se les llama personas jurídicas. Esta teoría es la que acepta nuestro Código Civil, según se desprende del artículo 545 y de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, pues existe una nota al proyecto de 1853, que alude a Savigny en este punto, gran sostenedor de esta teoría.

En todo caso, cabe hacer presente que nuestro Derecho, se aparta de la teoría de la ficción en muchas de sus consecuencias: por ejemplo, considera que las personas jurídicas poseen voluntad propia, circunstancia rechazada por Savigny.

En cuanto a la responsabilidad civil de las personas jurídicas por los delitos o cuasidelitos civiles o criminales cometidos por sus representantes, el artículo 58 del Código Procesal Penal, se aparta también de la solución dada por Savigny, pues el citado precepto hace responsable civilmente a las personas jurídicas por los daños que provoquen los delitos y cuasidelitos cometidos por sus representantes o dependientes, bajo el entendido que hayan actuado dentro de la esfera de sus atribuciones. Aún más, según referiremos, la Ley N° 20.393, modificada mediante la Ley N° 21.121, contempla responsabilidad penal para las personas jurídicas, por la comisión de ciertos delitos.

2) Teoría de la realidad, postula que las personas jurídicas no son entes ficticios, sino poderosas individualidades sociales, se trata de organismos sociales, es una realidad objetiva. Se vincula esta teoría con la concepción orgánica de la sociedad, que reconoce la existencia de múltiples órganos intermedios, entre el Estado y el individuo. Uno de tales, es la persona jurídica.

II. Teorías que niegan la personalidad jurídica.

1) Teoría del patrimonio colectivo: Sustentada por Planiol, quien afirmaba que "la idea de la personalidad ficticia es una concepción simple, pero superficial y falsa". Agrega que en verdad, estamos ante una "propiedad colectiva", que existe junto a la propiedad individual.

Señala que "Bajo el nombre de personas jurídicas o civiles, hay que entender la existencia de bienes colectivos, en el estado de formas o masas distintas, poseídas por grupos de seres humanos más o menos numerosos y substraídas al régimen de la propiedad individual. Por consiguiente, estas pretendidas personas no existen ni aun de manera ficticia". Concluye Planiol afirmando que no puede haber sobre la tierra, otros titulares de derechos que los individuos de la especie humana.

2) Teoría del patrimonio de afectación: Propuesta por los alemanes Brinz y Bekker, postula esta teoría que los derechos y las obligaciones no tienen necesariamente por base a las personas. Existirían patrimonios sin dueño, basados en la afectación a un fin único de todos los bienes que forman parte de ellos (Vodanovic, Antonio, Ob. Cit., pág. 496). Esta teoría es radicalmente opuesta a la de Planiol.

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. De derecho público: Nación, Fisco, Municipalidades, iglesias, etc. A ellas no se les aplican las reglas del Título XXXIII Libro I CC, que regula a las personas jurídicas (Art. 547 inc. 2º CC).

2. De derecho privado:

a) No persiguen fines de lucro: corporaciones y fundaciones. A ellas se les aplican las reglas señaladas.

b) Sí persiguen fines de lucro: sociedades. No se rigen por estas reglas. Pueden ser (entre otras clasificaciones):

- Civiles
- Comerciales

El Código Civil regula tanto las corporaciones y fundaciones como las sociedades civiles de personas (comanditas y colectivas civiles). La Sociedad Anónima es siempre mercantil. Art. 2059 y 2064 CC.

La jurisprudencia ha adoptado diversos criterios para distinguir entre personas jurídicas de derecho público y de derecho privado:

1) Iniciativa para la creación del ente: las personas jurídicas de derecho público obtienen su existencia en virtud de resoluciones de la autoridad, mientras que las de derecho privado emanan directamente de la iniciativa de los particulares.

2) Potestad Pública: las personas jurídicas de derecho público están dotadas de potestades públicas, vale decir, gozan de imperio, en virtud del cual pueden dictar normas de carácter obligatorio.

3) Naturaleza del fin: las personas jurídicas de derecho público tienen por objeto servir fines públicos, mientras que las de derecho privado cumplen con los objetivos señalados por los asociados o fundadores o persiguen la obtención del lucro.

4) Fuente de Recursos: en el caso de las personas jurídicas de derecho público provienen por lo general de todos los habitantes de la nación; en cambio, en las de derecho privado, provienen de aportes, donaciones, cuotas sociales, etc.

4.3.1 PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO

Las disposiciones de los artículos 545 y siguientes del Código Civil no se aplican, como se indica en el artículo 547, a las personas jurídicas de derecho público, en cuanto a la organización y administración de las mismas. En tales aspectos, se rigen por la Constitución, leyes administrativas y reglamentos de los servicios públicos. Lo anterior, no supone sin embargo, que tales personas jurídicas queden por completo excluidas del Código Civil: por ejemplo, rige el artículo 2.497 CC, respecto de la prescripción. Por lo demás, debemos tener presente que el Fisco, en sus relaciones contractuales con los particulares, queda sujeto a las normas del Derecho Civil como cualquier otro contratante.

Cabe señalar que la enumeración del artículo 547 CC no es taxativa o limitativa, sino meramente ejemplar, y por lo demás no podía ser de otra forma, pues las personas jurídicas de derecho público no son tales por mencionarlas el Código Civil, sino por disponerle así normas de derecho público. El Código Civil menciona las siguientes:

1. La Nación y el Fisco: debemos entender que al aludir a la Nación se refiere la ley al Estado, como lo prueba una nota de Andrés Bello. El Estado representa la organización política, jurídica y económica de la sociedad y de la sociedad nacional y constituye la fuente de todo el derecho (salvo la costumbre); por ello es la persona jurídica por excelencia y se fija a sí misma las condiciones para el desarrollo de su actividad y aquellas para el desarrollo de toda actividad pública o privada.

Cuando el Estado interviene como titular de potestades públicas, mantiene su denominación, y cuando interviene como titular de derechos subjetivos privados, se le denomina Fisco.

2. Las Municipalidades: Son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas (Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades).

3. Iglesias y Comunidades religiosas: a pesar de que el Código Civil habla en forma general y sin distinguir el tipo de culto de que se trata, debe concluirse que se refiere exclusivamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por una razón muy simple: era la única que podía existir, conforme a la Constitución de 1833, vigente a la promulgación del Código Civil en 1857.

Por "Iglesias" se entienden las distintas subdivisiones de la Iglesia Católica a las que el Derecho Canónico reconoce personalidad, entre ellas: Iglesia Catedral, Iglesia Parroquial, etc.

Por "Comunidad religiosa", se alude a las órdenes y congregaciones.

La parte final del inciso 2 del artículo 547, establece expresamente que las personas jurídicas de derecho público se rigen por leyes y reglamentos especiales.

Aplicando esta norma a la Iglesia Católica y a las comunidades religiosas, se concluye que las leyes y reglamentos especiales que las rigen son sus constituciones y leyes canónicas (así ha fallado la jurisprudencia).

4. Establecimientos que se costean con fondos del erario: sin embargo, del artículo 547 CC no debe desprenderse que todo establecimiento que se costea con fondos del erario es una persona jurídica de derecho público. Hay algunas que carecen de personalidad jurídica; por otra parte, hay instituciones privadas que reciben auxilios fiscales o municipales y no por ello tienen personalidad jurídica de derecho público. En realidad, son personas jurídicas de derecho público los "establecimientos públicos". Estos son ramas de los servicios generales del Estado o municipios, que se han desprendido del conjunto para erigirse en órganos dotados de vida propia.

4.3.2 PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO

El 17 de febrero de 2012 entró a regir, después de un año de vacatio legis, la ley N° 20.500, de 16 de febrero de 2011, que contiene la mayor reforma que haya sufrido la regulación de las personas jurídicas sin fines de lucro contemplada en el Código Civil. Hay muchos aspectos que podrían comentarse

de ella, pero la principal a nuestro juicio es la flexibilización de la forma de constitución de las corporaciones o fundaciones.

De acuerdo con la filosofía del Código Civil, aunque adelantado para su época (fue el primero en regular la personalidad jurídica siguiendo las ideas de Federico von Savigny), las personas jurídicas privadas sin fines de lucro debían estar sometidas fuertemente al poder gubernamental. Se desconfiaba de que fueran realmente altruistas y no una forma encubierta para realizar actividades contrarias al orden público. Prevalecía la idea de que la personalidad jurídica era una especie de cobertura ficticia, formal, que el legislador o el Gobierno (el Presidente de la República), podía conceder o denegar a una agrupación o un patrimonio para conseguir un fin de bienestar general no lucrativo. Por ello, salvo intervención directa de la ley, para crear una corporación o fundación debía recorrerse un largo camino, que comenzaba con el otorgamiento de los estatutos, seguía con una solicitud al Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, un examen del Consejo de Defensa del Estado, observaciones de éste, enmienda de los defectos detectados, hasta finalmente, emisión de un decreto supremo por el cual se concedía la personalidad jurídica, el que debía publicarse en el Diario Oficial. En la mayoría de los casos, organizar una corporación o fundación podía tomar entre seis meses a un año, sino más.

Entre tanto cambió la comprensión jurídica de las personas jurídicas sin fines de lucro, que pasaron a ser vistas como un modo de participación de la sociedad civil en la satisfacción de las necesidades de los más vulnerables y en la búsqueda de la integración y la participación de los distintos segmentos sociales. Cambió también el contexto normativo, ya que la constitución de personalidad jurídica, aunque sometida a los requisitos que fije la ley, es concebida por la Constitución como una emanación del derecho fundamental de asociación (art. 19 N° 15 Const.). También la doctrina civil moderna ha destacado la importancia de las personas jurídicas sin fines de lucro, ya no como una mera ficción legal, sino como instrumentos necesarios para el desarrollo de fines humanos que no son alcanzables con esfuerzos meramente individuales.

Por eso, aunque en general la civilística nacional fue sorprendida, cuando en pleno febrero de 2011, se modificó sustancialmente la regulación de las corporaciones y fundaciones, liberándose su forma de constitución, en realidad era un cambio que se veía venir hace mucho tiempo y era plausible que alumbrara en el texto de una ley que tenía por finalidad fomentar las asociaciones y la participación ciudadana⁵.

⁵ Comentario de Hernán Corral Talciani

1. Corporaciones y fundaciones.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

- Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones. Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados.
- Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general.

Ambas tienen en común la persecución de un fin, naturalmente lícito, no lucrativo y determinado. La diferencia está en que es la reunión de personas la que determina a la corporación; la existencia de bienes no es indispensable, como sí lo es en las fundaciones.

2. Constitución

- Instrumento: El acto por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones constará en escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde.

En el caso de las fundaciones, para su creación es fundamental un fundador, que puede hacerlo:

1. Por medio de una asignación testamentaria. No es necesario que sea directa, sino que puede tener el carácter de asignación modal.
2. Por acto entre vivos. Declaración unilateral del fundador y es un acto solemne.

- Depósito en Secretaría Municipal: Copia del acto constitutivo, autorizada por el de fe o funcionario ante el cual fue otorgado, deberá depositarse en la secretaria municipal del domicilio de la persona jurídica en formación, dentro del plazo de 30 días contado desde su otorgamiento. Este plazo no regirá para las fundaciones que se constituyan conforme a disposiciones testamentarias.

- Posible objeción del secretario: Dentro de los 30 días siguientes a la fecha del depósito, el secretario municipal podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación o fundación, si no se hubiere cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia.

- Notificación al solicitante: La objeción se notificará al solicitante por carta certificada. Si al vencimiento de este plazo el secretario municipal no hubiere notificado observación alguna, se entenderá por el solo ministerio de la ley que no objeta la constitución de la organización, y se procederá de conformidad al inciso quinto del Art. 548 CC.

- Enmienda de las observaciones: Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales procedentes, la persona jurídica en formación deberá subsanar las observaciones formuladas, dentro del plazo de 30 días, contado desde su notificación. Los nuevos antecedentes se depositarán en la secretaría municipal. El órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos las modificaciones que se requieran para estos efectos.

- Envío de los antecedentes al Registro Civil para su inscripción: Si el secretario municipal no tuviere objeciones a la constitución, o vencido el plazo para formularlas, de oficio y dentro de quinto día, el secretario municipal archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y los remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa. La asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir de esta inscripción.

3. Responsabilidad de los individuos que componen la corporación:

Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una corporación, no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, si se estipula expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.

Si una corporación no tiene existencia legal según el artículo 546, sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente.

4. Asamblea en las corporaciones:

La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una asamblea o reunión legal de la corporación entera.

La asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades de la asociación.

La voluntad de la mayoría de la asamblea es la voluntad de la corporación.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto.

5. Dirección y administración en las asociaciones:

La dirección y administración de una asociación recaerá en un directorio de al menos tres miembros, cuyo mandato podrá extenderse hasta por cinco años.

No podrán integrar el directorio personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva.

El director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito, o incurriere en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesará en sus funciones, debiendo el directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el período del director reemplazado.

El presidente del directorio lo será también de la asociación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.

El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del que presida.

El directorio rendirá cuenta ante la asamblea de la inversión de los fondos y de la marcha de la asociación durante el período en que ejerza sus funciones.

Cualquiera de los asociados podrá pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como de sus actividades y programas.

6. Gratuidad en el ejercicio del cargo de director:

Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.

Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo contrario, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la asamblea o, tratándose de fundaciones, al directorio.

La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación encomiende alguna función remunerada.

7. Responsabilidad del director:

En el ejercicio de sus funciones los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a la asociación.

El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio, deberá hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima asamblea.

8. Patrimonio de las asociaciones y fundaciones:

Las asociaciones y fundaciones podrán adquirir, conservar y enajenar toda clase de bienes, a título gratuito u oneroso, por actos entre vivos o por causa de muerte.

El patrimonio de una asociación se integrará, además, por los aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos.

Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación no podrán distribuirse entre los asociados ni aún en caso de disolución.

9. Fiscalización de las asociaciones y fundaciones:

Corresponderá al Ministerio de Justicia la fiscalización de las asociaciones y fundaciones.

En ejercicio de esta potestad podrá requerir a sus representantes que presenten para su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del desarrollo de sus actividades.

El Ministerio de Justicia podrá ordenar a las corporaciones y fundaciones que subsanen las irregularidades que comprobare o que se persigan las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas que fueren necesarias para proteger de manera urgente y provisional los intereses de la persona jurídica o de terceros.

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia se mirará como infracción grave a los estatutos.

10. Actividades económicas de las asociaciones y fundaciones:

Las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines. Asimismo, podrán invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración.

Las rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio.

11. Modificación de los estatutos de una asociación y fundación:

La modificación de los estatutos de una asociación deberá ser acordada por la asamblea citada especialmente con ese propósito. La disolución o fusión con otra asociación deberán ser aprobadas por dos tercios de los asociados que asistan a la respectiva asamblea.

Los estatutos de una fundación sólo podrán modificarse por acuerdo del directorio, previo informe favorable del Ministerio, siempre que la modificación resulte conveniente al interés fundacional. No cabrá modificación si el fundador lo hubiera prohibido.

El Ministerio de Justicia emitirá un informe respecto del objeto de la fundación, como asimismo, del órgano de administración y de dirección, en cuanto a su generación, integración y atribuciones.

12. Disolución de las asociaciones y fundaciones:

Las asociaciones se disolverán:

- a) Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiera;
- b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, cumpliendo los requisitos formales establecidos en el artículo 558;
- c) Por sentencia judicial ejecutoriada, en caso de:
 - 1) estar prohibida por la Constitución o la ley o infringir gravemente sus estatutos, o
 - 2) haberse realizado íntegramente su fin o hacerse imposible su realización, y
- d) Por las demás causas previstas en los estatutos y en las leyes.

La sentencia a que se refiere la letra c) precedente sólo podrá dictarse en juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, en procedimiento breve y sumario, el que ejercerá la acción previa petición fundada del Ministerio de Justicia. En el caso a que se refiere el número 2 de la letra c) precedente, podrá también dictarse en juicio promovido por la institución llamada a recibir los bienes de la asociación o fundación en caso de extinguirse.

Las fundaciones perecen, además, por la destrucción de los bienes destinados a su manutención.

13. Bienes de la asociación y de la fundación luego de la disolución:

Disuelta una corporación, se dispondrá de sus propiedades en la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades al Estado, con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución. Tocaré al Presidente de la República señalarlos.

4.4 ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Nombre y domicilio.

Las corporaciones y fundaciones establecen su nombre y domicilio desde su origen, pues deben indicarse en los estatutos. En las corporaciones generalmente el nombre tiene relación con el objeto que se persigue. En las fundaciones, la regla general es que diga relación con la persona del fundador.

En las sociedades civiles no hay norma, pero se da por sentado que debe existir una razón social (Art. 2062 CC).

En las sociedades comerciales colectivas y en comandita, el nombre y domicilio deben estar en la escritura social, al igual que en las S.A.

Si el nombre de una S.A. es igual al de otra, ésta tiene derecho a demandar su modificación.

En caso de litigio, los tribunales pueden determinar si el domicilio efectivo de la sociedad corresponde al fijado por los estatutos.

Es aplicable a las personas jurídicas el Art. 67 CC: si concurren en varias secciones territoriales circunstancias constitutivas del domicilio, lo tiene en todas.

2. Nacionalidad.

Tradicionalmente hay 2 criterios:

1. La nacionalidad de una sociedad es la del país en que se ubica su sede social (criterio de Europa continental).
2. La nacionalidad es la del Estado que la autorizó (criterio de common law).

Con las guerras mundiales, se estableció una analogía entre las reglas que

rigen la nacionalidad de las sociedades y las que rigen la de los individuos, a fin de otorgarles protección diplomática.

Pero se generaron otros problemas. Ej. Ciudadanos de un país constituían una sociedad en un país distinto para que tuviera la nacionalidad de éste, y así realizar actos que le era prohibidos o ilícitos personalmente.

Por ello surge la teoría del control: la nacionalidad de una sociedad está determinada por la nacionalidad de las personas que controlan sus decisiones. Pero en 1970, la Corte Internacional de Justicia descartó este criterio.

Entre nosotros, es la autorización, o sea, la constitución en Chile lo que determina la nacionalidad chilena, es decir, se sigue el criterio utilizado de acuerdo al Common Law.

3. Patrimonio.

Las personas jurídicas tienen un patrimonio propio distinto del de las personas naturales. Pero en las personas jurídicas puede tener un carácter fundamental que no lo tiene en las personas naturales: el patrimonio con un valor positivo, como continente de bienes, puede ser indispensable para la subsistencia de la personalidad. Ej. Causal especial de disolución de las fundaciones.

4. Capacidad.

Las personas jurídicas son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente (Art. 545 CC).

Esta capacidad está restringida a los derechos patrimoniales; los derechos de familia son sólo compatibles con la persona natural.

Aun dentro de los derechos patrimoniales, hay ciertos derechos personalísimos que no entran dentro de la capacidad de las personas jurídicas: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal (Art. 1618 N° 9 CC). Ej. Uso y habitación.

Ciertos cargos sólo pueden ser desempeñados por personas naturales. Ej. Partidores, albaceas, depositarios (salvo excepciones).

En general, la capacidad de la persona jurídica está determinada y subordinada a su tipo y finalidad.

5. Derechos de la personalidad.

En relación a este atributo en particular, se discute si efectivamente lo poseen o no las personas jurídicas atendida la naturaleza de los derechos y a su vez de la persona en comento. Ahora bien, se ha entendido que podría llegar a tener alguno de estos derechos en la medida que lo permitiera su naturaleza

incorporea. Por lo tanto, no contarían con el derecho a la vida, y sí con derechos de la personalidad que tienen que ver más bien con la individualidad y libertad, tal como el derecho a reunirse y asociarse consagrado en el Art. 19 N° 13 y 15 CPR.

Esta última idea es también criticada, sosteniendo que en definitiva todo menoscabo a algún supuesto derecho de la personalidad de la persona jurídica tan sólo será tal si llega a dañar el patrimonio de la misma, por lo cual sería reconducible a dicho atributo careciendo en definitiva la persona jurídica de los derechos de la personalidad.

Esta discusión se seguirá desarrollando más adelante a propósito de la indemnización del daño moral sufrido por esta clase de personas.

4.5 RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1 Responsabilidad penal.

Este fue un tema discutido en doctrina:

1. Los que opinan que la personalidad jurídica es una ficción: la responsabilidad penal es imposible porque:

- a) Esta responsabilidad se basa en la voluntad del ser humano.
- b) Existe el principio de personalidad o individual de las penas.

2. Los que estiman que es una realidad objetiva: tienen responsabilidad penal, pero debe restringirse a casos excepcionales y a penas determinadas.

3. Los que sostienen que es una realidad abstracta: las personas jurídicas no pueden ser autoras de delito en el sentido natural; si por parte de una persona jurídica se cometiere un delito, no personal sino colectivo, debe ser castigado a través del derecho penal administrativo.

Entre nosotros, el Art. 58 inc. 2° CPP señala que la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

Tras la dictación de la ley 20.393⁶ de 2 de Diciembre de 2009 el tema fue zanjado, pues si bien con anterioridad el ordenamiento chileno había previsto esporádicamente sanciones en las que podían observarse penas contra las personas jurídicas, a través de esta ley se establecen sanciones de modo abierto y explícito. Se establece un verdadero sistema de responsabilidad penal propio de tales entidades, con explicitación de los presupuestos específicos de

⁶ Extracto del texto "La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile", Hernández Basualto, Héctor

la misma y de las circunstancias que la modifican, con penas y reglas de determinación también específicas y con las adaptaciones procesales básicas para su aplicación práctica.

Con esto se abandona — de un modo radical y, en buena medida, sorpresivo — el dogma tradicional *societas delinquere non potest*, consagrado legislativamente con carácter general en el art. 58 del Código Procesal Penal (en lo sucesivo, CPP), lo que en concreto sólo puede explicarse por el afán de cumplir oportunamente con las exigencias de las que dependía la incorporación de Chile a la OCDE, en particular de las contenidas en la Convención de dicho organismo en materia de cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de 21 de noviembre de 1997.

Porque, en efecto, atendido el conocido desinterés del legislador chileno por atacar la criminalidad de empresa, la postura poco entusiasta y más bien renuente del conjunto de la doctrina nacional hacia la punibilidad de las personas jurídicas y la escasez previa de iniciativas legislativas en ese sentido, sin el factor externo hubiera sido apenas imaginable un giro tan radical. No es casual, entonces, la importancia que el Mensaje del Ejecutivo (Boletín 6423-07) le atribuye no ya al cumplimiento de compromisos internacionales, sino específicamente al inminente ingreso como miembro pleno de la OCDE, importancia que se destacó a lo largo de toda la tramitación.

Curiosamente la Convención no prescribe el establecimiento de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino sólo que las sanciones que en virtud de la misma se impongan a dichas personas sean "eficaces, proporcionadas y disuasivas". En el caso chileno, sin embargo, la ausencia de un sistema realmente efectivo de sanciones extrapenales para estas entidades y el tratamiento previo poco diligente del asunto por parte de las autoridades responsables, unido probablemente a una cierta preferencia de la Convención — y de los órganos de control de su cumplimiento — por el establecimiento de una responsabilidad penal, hizo que en algún momento de las negociaciones el campo de maniobra del Estado chileno se redujera al mínimo y en los hechos sólo resultara satisfactorio un mecanismo inserto en el sistema de justicia criminal, por lo demás el único disponible con la cobertura necesaria para cumplir a tiempo. En este contexto, además, y en concordancia con el modelo adoptado, fue necesario reconocer el carácter penal de la responsabilidad atribuida a las entidades.

De este modo la Ley Nº 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica (modificada por la ley 21.595 de Delitos Económicos) vino a resolver una cuestión crucial para la configuración del ordenamiento penal chileno en un contexto de urgencia, con poco espacio para una reflexión académica profunda al respecto.

En lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley, ésta se aplica a las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley; las

empresas, sociedades y universidades del Estado; los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público (art. 2º de la Ley Nº 20.393), sin distinción de tamaño.

En tanto que, en lo que concierne a los delitos que dan lugar a la responsabilidad penal de las mismas,

en vez de una previsión general, se consagra con esta ley un catálogo cerrado de tipos penales, inicialmente los siguientes (art. 1º):

- a) Lavado de dinero (art. 27 de la Ley Nº 19.913, Ley que crea la Unidad de Análisis Financiero).
- b) Financiamiento del terrorismo (art. 8º de la Ley Nº 18.314, ley sobre conductas terroristas).
- c) Soborno o cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales (art. 250 del Código Penal [en lo sucesivo, CP]) como de funcionario público extranjero (art. 251 bis CP).

Como se puede ver, la Ley 20.393 en sus inicios trataba de un catálogo extraordinariamente restringido, que en lo fundamental abarca sólo las materias respecto de las cuales existía obligación internacional de sancionar a las personas jurídicas, las que, por lo demás, tienen una relativamente escasa aplicación práctica, sin perjuicio del ámbito no despreciable de aplicación que debería asegurar la consideración del soborno doméstico. Durante la tramitación de la ley se hizo presente reiteradamente que quedaban fuera del catálogo los delitos de mayor trascendencia relacionados con la actividad empresarial. Sin embargo, las iniciativas para revertir esa situación no fueron acogidas en un primer momento, apelándose para ello a la prudencia inicial que demandaba una innovación tan significativa. Esta razón podrá no ser muy convincente, pero en cuanto reconoce abiertamente la excesiva circunspección del catálogo, al menos dejó la puerta abierta para la futura incorporación de un conjunto de figuras relevantes.

En este último sentido es que se dicta la Ley Nº 21.121, publicada el 20 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial que modifica las normas sobre corrupción y otros delitos, creando nuevos tipos penales y ampliando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, esta ley vino a reformar tanto la Ley Nº 20.393, el Código Penal y la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, en lo relativo a diversas conductas penales relacionadas con la corrupción y conflictos de interés.

En relación específicamente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley establece las siguientes principales modificaciones respecto de la responsabilidad penal de ellas:

1. Ampliación de delitos base: La Ley duplica el número de delitos que pueden servir de base para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, agregando los siguientes: (i) Negociación incompatible, (ii) Corrupción entre particulares, (iii) administración desleal y (iv) Apropiación indebida (Art. 470 Nº CP).

2. Aumento de penas: La Ley (i) establece la posibilidad de aplicar la pena de disolución de la persona jurídica a todos los delitos base de la Ley Nº 20.393, siempre que el autor haya cometido previamente un delito de la misma especie, (ii) aumenta el máximo de multas aplicables de 20.000 UTM a 300.000 UTM; y (iii) agrega como penas accesorias la pena de comiso por equivalencia y el comiso de las ganancias que se hubieren obtenido del ilícito.

Finalmente, el año 2023 se publica la ley 21.595 de Delitos Económicos que modifica, entre otros cuerpos normativos, a la presente ley Nº 20.393 y presenta un conjunto de modificaciones a la señalada normativa, destacando las siguientes:

1. Amplía el ámbito de delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente, incluyendo en la actualidad los siguientes:

a) Los delitos a los que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley.

b) Los previstos en el artículo 8 de la ley Nº 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad; en el Título II de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y en los artículos 411 quáter, 448 septies y 448 octies del Código Penal.

2. Precisa qué entidades serán penalmente responsables: tal como se señaló con anterioridad, se comprende a las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley; las empresas, sociedades y universidades del Estado; los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho.

3. Establece presupuestos de la responsabilidad penal: Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, perpetrado en el marco de su actividad por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos, por parte de la persona jurídica.

Si concurrieren los requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

4. Determina la autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de

declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta, a pesar de la ilicitud del hecho, no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho. Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que conste que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3.

4. Señala penas aplicables a la persona jurídica:

1. La extinción de la persona jurídica.
2. La inhabilitación para contratar con el Estado.
3. La pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos.
4. La supervisión de la persona jurídica.
5. La multa.
6. El comiso a que se refiere el inciso tercero del artículo 14.
7. La publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.

2. Responsabilidad civil.

1. En materia contractual, las personas jurídicas responden de todas las obligaciones contraídas en su nombre por sus representantes si éstos han obrado dentro de los límites de su mandato. Arts. 552 y Art. 563 CC.
2. En materia extracontractual, la persona jurídica puede incurrir en ella, pues no hay ninguna norma que la limite a las personas naturales, como la norma del CPP. Además, si el Art. 545 CC señala que puede contraer obligaciones civiles, no hay razón para excluir una de sus fuentes.

Se ha sostenido que el delito o cuasidelito debe haber sido cometido por los "órganos" de la persona jurídica, es decir, por las personas naturales o asamblea en que reside la voluntad de la persona jurídica. Así, el daño inferido por un miembro que no tenga representación sólo puede hacer responsable a la persona jurídica por el mecanismo de la responsabilidad por el hecho ajeno.

Esta teoría confunde la capacidad para contraer responsabilidad contractual y extracontractual. En esta última, el Art. 2319 CC dice que los únicos incapaces son los infantes (menores de 7) y los dementes, lo que es lógico pues nos encontramos ante hechos jurídicos, no actos. En consecuencia, para que la persona jurídica contraiga responsabilidad extracontractual no es necesario que actúen las personas que la representan. Incurre en esta responsabilidad por los daños que produzca su actividad, realizada por medio de cualquiera de sus miembros.

En cuanto a la responsabilidad por el hecho ajeno, el Art. 2320 CC no tiene limitaciones e incluso señala como ejemplo la de los empresarios por sus dependientes (empresario: persona natural o jurídica que ejecuta una obra o explota un servicio).

4.6 PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS⁷.

En el contexto de los cambios que experimentó la sociedad durante el siglo XX, no es casual que emergiera con fuerza la discusión sobre la naturaleza y alcances del daño moral de la mano de la expansión de la responsabilidad civil.

Los problemas que el daño moral planteó obligaron a los tribunales a asumir con cautela cada uno de ellos, siendo un trabajo que abarcó el examen de su procedencia en la responsabilidad contractual, su prueba y los criterios para su apreciación, entre otros.

Así las cosas, era inevitable que la especial naturaleza de las personas jurídicas alimentara al ya complejo problema del daño moral, lo que obliga a confrontar las características de ambas figuras en la búsqueda de la respuesta de si puede o no una persona jurídica ser sujeto pasible de un daño moral y, en consecuencia, tener legitimación activa para poder demandar su resarcimiento.

Estando afincado el concepto del daño moral fuera del ámbito pecuniario, indudablemente que la primera cuestión que surge raya entre lo jurídico y lo ontológico: ¿pueden o no las personas jurídicas sufrir un daño moral? Esto es, si pese a ser entes carentes de una realidad física pueden padecer perjuicios en la esfera de lo intangible y lo inconmensurable. Esta controversia se encuentra íntimamente unida a uno de los conceptos más intrincados y reformados por la doctrina jurídica a lo largo de la historia, cual es la noción de persona, concepto que fue especialmente reexaminado precisamente en el siglo XX.

Una primera reacción fue rechazar con firmeza la posibilidad de que una persona jurídica pudiera demandar daños de este carácter. Según se dijo, la legitimidad de este tipo de personas pugnaría con el hecho de que se trata de entes ficticios, incapaces de tener sensaciones como el sufrimiento, la depresión o la angustia y que, en tanto tales, jamás podrían padecer un daño fuera de su patrimonio. Lo anterior, se afirmaba, sería coherente con la finalidad instrumental de las personas jurídicas, quienes no tienen una dignidad intrínseca como los seres humanos, dada por su propia naturaleza, sino exclusivamente en virtud de la ley y para obrar dentro de los márgenes que el ordenamiento le reconoce. La proclama pareciera ser, al final, que el derecho permite ensanchar la personalidad a otros sujetos que los seres humanos, pero la humanidad sigue siendo exclusiva de nuestra especie, al punto que esta sería la única que tiene derechos anteriores y superiores al Estado.

⁷ Profesor Cristián Boetsch Gillet: Daño Moral en las Personas Jurídicas. Revista El Abogado - Colegio de Abogados de Chile.

A la par con el auge de la doctrina de los derechos de la personalidad, la conclusión anterior fue refutada. Así, siendo indiscutible que una persona jurídica no puede sufrir, por ejemplo, ello no la priva del reconocimiento que el derecho le hace de toda una gama de atributos que los seres humanos también compartimos, que se estiman inherentes a la personalidad en sí y son indispensables para un pleno y libre desarrollo en una sociedad, como el domicilio, el nombre, la imagen o el honor. Por cierto, un ataque a la reputación de una persona jurídica no tiene ninguna relevancia subjetiva para un ente que no posee sentimientos y no tiene estima sobre sí mismo. Pero ello no impide que objetivamente exista una lesión en la realidad que afecta a la persona jurídica en la percepción que terceros tienen sobre esta, la que se erosiona como resultado de una conducta imputable a culpa o dolo de una persona autora del daño. Negar este aspecto de las personas jurídicas degradaría el concepto mismo de personalidad; esta quedaría reducida solamente a un patrimonio con independencia de los complejos e indivisibles factores que la componen.

La idea misma de daño moral también ha sufrido varios cambios desde su irrupción como un aspecto importante del estudio del derecho. Como es sabido, el daño moral transitó desde una concepción limitada a los sentimientos de una persona hacia una cada vez mayor ampliación de una lista interminable de rubros, como el daño biológico, la pérdida del agrado de vivir, el perjuicio estético, etc. Por lo mismo, la mayoría de la doctrina reserva hoy el nombre de daño moral solamente a una especie determinada de los perjuicios que no pueden evaluarse económicamente, que corresponde a la aflicción o pesar padecido por la víctima de la acción: el también llamado “pretium doloris”. Se prefiere denominar el género como daños extrapatrimoniales o inmateriales - que, en forma eufemística, pero forzada, algunos autores estiman afectarían el “patrimonio ideal” de un sujeto en oposición a su “patrimonio material”-.

Es evidente que el daño moral, en su acepción moderna y restringida, no puede ser experimentado por una persona jurídica, lisa y llanamente porque esta no puede sufrir tristeza alguna. De ahí que la doctrina haya tenido que levantar la mirada en busca de otros rubros en los cuales identificar las lesiones extrapatrimoniales de estas entidades.

Actualmente, la fundamentación del daño extrapatrimonial de las personas jurídicas más arraigada en Chile y en el derecho comparado, consiste en determinar que solo son indemnizables aquellos menoscabos que, si bien no inciden en el patrimonio de una persona, proyectan sus consecuencias nocivas en el patrimonio de la víctima. Sería de esta naturaleza, por ejemplo, la situación de la empresa que, debido a la publicidad infundada sobre la mala calidad de sus productos, ve reducido su número de clientes. O el caso real ocurrido en España de la empresa que es incluida indebidamente en un registro de deudores morosos, viendo afectada su capacidad de crédito. Como es posible observar, esta postura pareciera seguir la misma línea de

razonamiento del artículo 2331 del Código Civil, pese a que dicha disposición no ha sido invocada como sustento en los fallos que han adherido esta posición. No altera este razonamiento el que tal norma haya sido declarada inaplicable varias veces por el Tribunal Constitucional, no obstante el mismo no hace mucho rechazó un requerimiento de inconstitucionalidad de ella.

La crítica que ha debido enfrentar esta doctrina es la asimilación de la consecuencia pecuniaria de una conducta dañosa como un asunto extrapatrimonial: si el daño repercute en la esfera del patrimonio, malamente puede ser catalogado como inmaterial, no tratándose de un perjuicio extrapatrimonial. En razón de lo anterior, hay quienes han llamado a no confundir las consecuencias del hecho: un mismo comportamiento puede dar lugar a resultados perjudiciales tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, los que deben ser indemnizados si se dan las condiciones necesarias para ello. Particularmente en el caso de los daños inmateriales, que lesionen objetivamente los derechos de la personalidad de una persona jurídica.

Un examen breve de la jurisprudencia nacional permite comprobar el desarrollo que esta discusión ha tenido en nuestro país, donde, al igual que en otros, ha oscilado sin una postura exclusiva entre las distintas doctrinas que hemos expuesto anteriormente.

Un primer pronunciamiento que ineludiblemente no podemos dejar de lado es un muy acabado fallo por el que la Excma. Corte Suprema descartó de plano la hipótesis de que una persona jurídica pudiera sufrir perjuicios exclusivamente extrapatrimoniales, siendo indemnizables solo aquellos que tuvieran consecuencias patrimoniales al verse afectado el prestigio o la confianza comercial de la víctima (Excma. Corte Suprema, 9 de diciembre de 2003, número de ingreso 4677-1999).

De ahí en adelante, pareciera haberse establecido dicho criterio como el principal dentro de la jurisprudencia chilena para revisar la legitimación activa de las personas jurídicas y reclamar la indemnización de estos perjuicios, dejando atrás la visión que denegaba sin más la procedencia de la reparación de estos. Se ha resuelto que "lo que debe verse afectado es la reputación de la persona jurídica y ella solo si tiene trascendencia en la situación económica (...) y no por el solo hecho de lesionar la reputación" (Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, 18 de octubre de 2011, número de ingreso 768-2011); que en relación a las personas jurídicas "cabe descartar a su respecto el concepto de daño moral puro y centrarnos en el daño moral con consecuencias patrimoniales" (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 23 de noviembre de 2009, número de ingreso 6875-2011); o que "para pretender ser indemnizado por el daño a la imagen de una empresa, es necesario demostrar que ha existido lesión a la imagen de una empresa, y acreditar, de una manera cierta, las consecuencias económicas en que se ha traducido ese desprestigio" (Excma. Corte Suprema, 31 de octubre de 2012, número de ingreso 3325- 2012). Existen, sin embargo, otras sentencias minoritarias que han denegado

la indemnización de este rubro de perjuicios (por todas, Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, 29 de septiembre de 2008, número de ingreso 3688-2004).

Cabe destacar, además, que existe uniformidad en que la satisfacción de los daños extrapatrimoniales procede tanto en sede contractual como extracontractual, y que estos siempre deben ser acreditados por el actor.

Se trata, como puede verse, de un tema abierto y sumamente discutible, cuya solución es necesario alcanzar sin sacrificar conceptos tan indispensables como el de la personalidad o el principio de la responsabilidad. Por el contrario, en pos de su plena aplicación y respeto, debe perfeccionarse.